

共識與歧異^{*}

—— 司法院大法官解釋的數量危機

陳英鈴^{**}

摘要

為什麼司法院大法官解釋案件量少，而分別意見書量大？司法院認為現行法要求大法官解釋憲法，必須三分之二同意為主因，憲法訴訟法將憲法解釋門檻降為現有總額過半數，預計2022年實施。鑒往未必知來，憲法訴訟法否能發揮預期作用，一般審慎樂觀。本文在新法實施之前，反思大法官解釋為何解釋案件量少，而分別意見書量大的結構因素。本文藉助策略互動模型印證司法院的看法，同時發現高門檻導致司法院大法官防衛性駁回聲請，法官聲請案受理機率較高，少數立委聲請因選制變更變得困難，舉行言詞辯論等同預告案件（部分）違憲。少數大法官否決權導致爭議性案件久拖未決，妥協出來的解釋往往橫看成嶺側成峰，協同或不同意見書具有澄清個別大法官意見作用。這些複雜的結構因素，有哪些將隨新法而改變，又有哪些仍持續不變，有待進一步研究解答。

關鍵詞：策略行為模型、解釋案件變少、分別意見書、解釋門檻、橫看成嶺側成峰。

* 本文特別感謝雲思綺（國立中央大學法律與政府研究所碩士）在統計與繪圖上面的協助。在資料建檔上，還要感謝國立中央大學法律與政府研究所碩士潘元寧、鍾依庭、碩士生黃馨德等人協助。本文為科技部補助計畫（103-2410-H-008-018-MY2）部分研究成果，特此感謝科技部補助。
〔責任校對：陳昕婕、鄭雅文〕。

** 國立中央大學法律與政府研究所教授。
穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/10116002.pdf>。



目 次

壹、司法院大法官解釋的數量危機	二、大法官對法官聲請案的選擇
貳、研究進路	三、大法官對立法委員聲請案的選擇
一、分析模型	四、言詞辯論與解釋正當性
二、統計方法說明	五、解釋時間的策略選擇
參、危機的歷史起源與轉變	六、合議制變化與互動策略
一、高解釋門檻壓抑解釋數量	七、橫看成嶺側成峰
二、分別意見書的作用	伍、結論
肆、危機與其他制度的關連	
一、大法官對人民聲請案的選擇	

壹、司法院大法官解釋的數量危機

近年來各界對於大法官解釋案件量越來越少¹，不同或協同意見卻越來越多紛紛表示疑慮²。大部分的聲請釋憲案件都在程序審查即被駁回。這樣的運作方式，和一般認定的憲法守護神有一定的落差。為何大法官解釋變少、歧異變大？司法院認為，依現行司法院大法官審理案件法（以下簡稱：大審法）第14條第1項，「大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意，方得通過。但宣告命令牴觸憲法時，以出席人過半數同意行之。」³「違憲也要三分之二、合憲也要三分之二，始終無法做成違憲或合憲的決定，所以案子都卡在那個地方，也很受國人的關切，

¹ 蘇彥圖，釋憲時刻——初探司法院大法官的議程設定及其憲政效應，憲政時代，39卷4期，頁41（2014年）。

² 例如立委王惠美立法院發言「大法官審理程序歷年來最為人詬病的，不外乎審查時間過長、案件不受理的比例很高、不受理的理由很空泛」，請見立法院公報，102卷23期（下冊），頁218，王惠美委員發言（2013年）。

案子弄那麼久都做不出來。³」依現行解釋實務，大法官解釋憲法，通常都是15位大法官出席，出席三分之二的門檻是10位。現行法的矛盾表現為，越是要求解釋有高共識/門檻，解釋量越少，而每個解釋的分別意見書越多，越沒有形式上的共識。

有鑒於此，2019年1月4日憲法訴訟法公告，三年後實施。憲法訴訟法第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」解釋憲法的門檻降低為現有總額15位大法官過半數同意，亦即至少要有8票⁴。司法院秘書長樂觀表示「表決門檻改為二分之一，所以將來每個大法官都會配置助理法官一至兩名來協助，我推測產量應該會大增。⁵」鑒往未必知來，制度演變常出人意料之外，甚至與改革初衷背道而馳⁶，新制否能發揮預期作用，本文審慎樂觀，但尚難預測。對過去建構採什麼樣的觀點，影響了對現有問題的認知，同時也投射出未來的可能路徑圖。在憲法訴訟法兩年後實施之前，重新建構大法官解釋為何數量變少，歧異變大，對未來新法實施仍可提供相當反思。

從統計數字上看。現制確實有令人憂心之處。司法院統計資料顯示，司法院大法官2010年新收案件541件，不受理538件，做成14件解釋。2011年新收案件567件，不受理437件，做成12件解釋。2012年新收案件618件，不受理522件，做成12件解釋。2013年新收

3 請見司法院秘書長呂太郎在立法院答詢，立法院公報，107卷66期，頁381，司法院秘書長呂太郎答詢（2018年）。

4 請見王處長碧芳的說明，立法院公報，107卷111期（下冊），頁488，王碧芳處長發言（2018年）。

5 司法院秘書長呂太郎在立法院司法委員會答詢，立法院公報，107卷66期，頁353，司法院秘書長呂太郎答詢（2018年）。

6 例如韋伯曾言「政治行動的最終結果，往往——不、恰恰經常——脫離其原先設想（Sinn）路徑；有時候，甚至是完全背道而馳。這完全是事實，甚至是整個歷史的一項基本事實。」*Max Weber, Politik als Beruf*, in: Mommsen/Wolfgang J. (Hrsg.), *Max Weber-Studienausgabe*, Bd. I/17, 1994, S. 35 (75-76).

案件553件，不受理517件，做成9件解釋。2014年新收案件488件，不受理496件，做成10件解釋⁷。2015年司法院大法官僅作成8件解釋，分別意見書仍高達49份⁸。2016年僅作成9件解釋，2017年作成16件解釋，2018年作成14號解釋，近兩年雖因新任大法官上任，解釋案件有明顯回升⁹，然與德國聯邦憲法法院，或美國最高法院解釋案件量相比，仍有相當落差。

自從司法院大法官於1958年引進不同意見書以來，不同意見書（以及隨後引進的協同意見書）出現的比例就很高，1970-1973年、1975-1976年、1979年每一號解釋都有不同意見書。2011年以後，每一號解釋也同時出現相當可觀的分別意見書（不同意見書與/或協同意見書），沒有任何解釋共識可言。這種百花齊放的解釋都是產生在解釋效率最低的年代，1970-1973年每年只有2至3件，1975-1976年每年只有3件，1979年也只有5件。從1993到2010年司法院大法官總共受理372件，平均每年20.67件，平均每年9件受理案件違憲，佔受理案件的43.5%。這18年當中共有468份分別意見書，平均每年有26份，平均每個解釋案件有1.29個分別意見書。從2011年迄今（2016年8月），司法院大法官總共受理56件，平均每年9.33件，平均每年5.67件受理案件違憲，佔受理案件的60.7%。這近六年當中共有402份分別意見書，平均每年有67份，平均每個解釋案件有7個分別意見書。每年平均受理案件量以及解釋違憲案件量減少，但受理案件違憲比例增加。

7 司法院網站，<http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p05.asp>（最後瀏覽日：2016年8月15日）。

8 立委呂學樟統計則顯示「從民國91年到101年，大法官會議共終結3911案，作成解釋的案件只有143件，不受理的案件3616件，不受理比率高達92.4%。」請見立法院公報，102卷23期（下冊），頁212，呂學樟委員發言（2013年）。

9 本文初稿發表於2016年12月，至2020年6月已經過三年半。為忠於初稿，若無特別說明，本文統計仍僅至2016年7月底、司法院釋字第739號解釋為止。關於統計數字的說明，初稿後則大幅改寫。

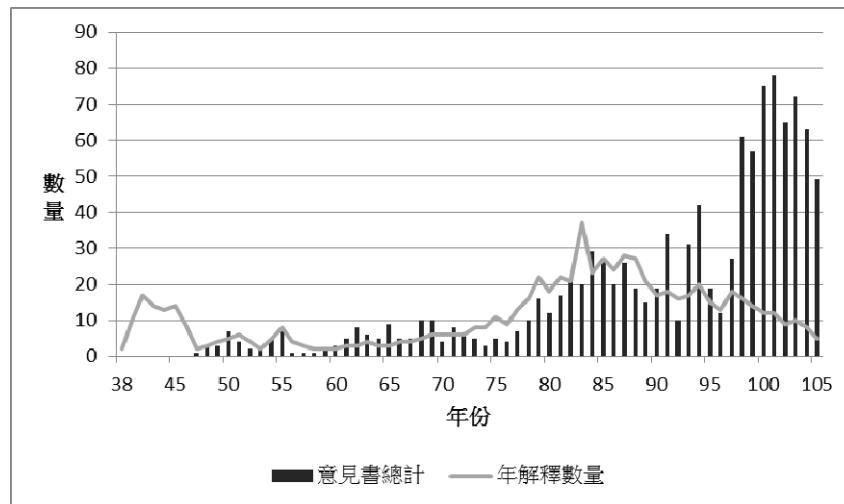


圖1 意見書與解釋數量對照圖

意見書計算方式為：協同+不同+部分協同部分不同+部分協同+部分不同之總數。

資料來源：作者自製。

對於受理案件越來越少，解釋歧異越來越大，前司法院長翁岳生教授語重心長表示：「大法官似應體認……如議決通過，各大法官還能寫不同意見或協同意見，隨同對外發表。假如第四屆大法官互不相讓，不但解釋不能通過，各大法官之任何意見都不能對外發表，有負國家之付託，即無法完成憲法所賦予之神聖使命。¹⁰」許宗力教授回顧2013年司法院大法官解釋，也發出警語：「一年（2013年）做成九件解釋的難堪記錄。¹¹」司法院釋字第729號解釋湯德宗部分協同暨部分不同意見書最後直指，司法院大法官「刻正面臨『解釋效率遞減』……及『意見分歧日增』……之瓶頸，非大刀闊斧改革，恐難符人民期許¹²。」吳信華認為：「現實上諸多不

¹⁰ 翁岳生，司法院大法官釋憲制度新發展，憲政時代，39卷4期，頁16（2014年）。

¹¹ 許宗力，2013年憲法發展回顧，臺大法學論叢，43卷特刊，頁1053（2014年）。

¹² 請見司法院釋字第729號解釋湯德宗大法官部分協同暨部分不同意見書，頁15。

同（協同）意見書的提出，反而可能更多的是個別大法官個人（學術）意見的貫徹陳述，而與前述法條（司法院大法官審理案件法施行細則第18條）所定內涵有所差異。¹³」縱然依司法院大法官審理案件法修改草案採行「個人主筆顯名」，「如果大法官『個人式』的思維未改，則問題依舊存在而無助於釋憲效率之提昇。¹⁴」楊子慧教授指出，個別意見書質量增長「已造成喧賓奪主之勢，甚有降低解釋公信力之虞。¹⁵」

本文採策略行為模型認為，現有解釋規則起源於司法院釋字第76號解釋引發立法院報復，制訂司法院大法官會議法，引進解釋高門檻與不同意見書，企圖限制違憲審查權、弱化其正當性。在此視角下，本文一同解釋其他制度的運作現象，例如人民聲請案漸增，大法官受理卻遞減。法官聲請案爭點整理較為清晰，有利於大法官受理。立法委員聲請解釋對民主化與民主鞏固有幫助，卻因立法委員選制變更被變相取消。大法官認為案件可能（部分）違憲才會舉行言詞辯論。協商困難案件費時甚久，只能等待時機。第四屆大法官透過非正式連誼，軟化高門檻限制。2003年後大法官個人意識抬頭，導致協商與妥協更加困難。透過橫看成嶺側成峰的解釋達成妥協等等。

大法官解釋乃大法官於內在與外在制度限制下，一連串策略互動的結果。隨著歷史時空的演變，制度對大法官產生不同的意義。大法官做成解釋的門檻，以及相關規定所形成的制度深刻地影響了為何大法官解釋變少、歧異變大。在策略互動理論的參考架構下，

13 吳信華，大法官釋憲「程序」與「實體」的交錯，月旦法學雜誌，226期，頁124（2014年）。

14 吳信華，二〇一三年「司法院大法官審理案件法修正草案」評析II，台灣法學雜誌，227期，頁15（2013年）。憲法訴訟法第32條第2項規定「判決書應記載參與判決之大法官姓名及其同意與不同意主文之意見，並標示主筆大法官。」

15 楊子慧，大法官解釋制度的司法化變革——憲法解釋的形成制度探討，東吳法律學報，25卷4期，頁58（2014年）。

本文將藉助統計資料分析¹⁶、既有文獻分析，以及大法官深度訪談¹⁷（以下「貳」），解釋為何司法院大法官解釋變少、歧異變大（以下「參」），因此造成違憲審查危機和解釋制度的關連性（以下「肆」），最後提出本文結論（以下「伍」）。

貳、研究進路

研究方法的選擇決定了答案的可能範圍。如何回答本文的基本問題，司法院大法官解釋為什麼解釋案件變少、歧異卻變大，本文採取的是策略行為模型（the strategic model），與此相對應的則是美國研究司法決策的另外兩種模型：法律解釋模型（the legal model）以及政治態度模型（the attitudinal model）¹⁸。本文認為三種模型重點各有不同，法律解釋模型（以下「一、（一）」）和政治態度模型（以下「一、（二）」）解釋了部分司法決策行為的現象，卻難以充分回答本文的基本問題。策略行為模型（以下「一、（三）」）重新架構法律解釋模型和政治態度模型的意涵，足以作為本文的參考模型，解釋統計資料分析（以下「二」）、既有文獻分析，以及大法官深度訪談的結果，說明為何司法院大法官解釋變少、歧異變大，因此造成的違憲審查危機。在進行分析之前，先對三種分析模型做扼要說明。

16 正如近代統計學大師Karl Pearson所言：「今日無人相信科學可以解釋任何事，吾人視科學為簡單的描述，思考經濟而已。」KARL PEARSON, THE GRAMMAR OF SCIENCE, at V (3d ed. 1911).

17 本文訪談三位大法官，非正式與一位大法官交談。為保護其隱私，故僅以大法官A. B. C. D.表示。

18 PAMELA C. CORLEY ET AL., THE PUZZLE OF UNANIMITY: CONSENSUS ON THE UNITED STATES SUPREME COURT 51-59 (2013). Posner列出政治態度的、策略的、社會學的、心理學的、經濟學的、組織的、實用的、與現象學的、法律解釋等九種方法。請見RICHARD A. POSNER, HOW JUDGES THINK 1-56 (2008).

一、分析模型

（一）法律解釋模型

法律解釋模型的依據為法治主義（rule of law）、法治國原則或憲法國家原則。司法院大法官為憲法上法官，依據憲法獨立審判¹⁹。既然依法解釋為憲法保障與義務，決定大法官司法行為的主要因素就是法的解釋²⁰。司法院大法官的現有解釋很少提到憲法解釋的一般性方法，司法院釋字第392號解釋僅提及「憲法並非靜止之概念，其乃孕育於一持續更新之國家成長過程中，依據抽象憲法條文對於現所存在之狀況而為法的抉擇，當不能排除時代演進而隨之有所變遷之適用上問題。從歷史上探知憲法規範性的意義固有其必要；但憲法規定本身之作用及其所負之使命，則不能不從整體法秩序中為價值之判斷，並藉此為一符合此項價值秩序之決定。」這個抽象論述對於個案解釋並無太大幫助²¹。

法律解釋模型無論依照哪種法律解釋方法²²，很難令人滿意地回答為什麼大法官解釋量變少，而歧異變大。難道經過這麼多年的司法院大法官釋憲，聲請釋憲者越來越不懂司法院大法官審理案件

19 司法院釋字第601號解釋：「憲法第八十條規定：『法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。』……大法官審理案件，常以國家機關為當事人，為期裁判公正，排除干涉，尤須以遵守憲法第八十條規定為其憲法上義務。惟審判獨立與身分保障之關係，密不可分」。

20 因篇幅所限，本文只是借用美國司法決策模型這個用語，但並不完全引用美國司法決策模型所引用的法律主義（legalism），而是主要分析國內討論問題時比較熟悉的法律解釋學，相當一部份會引用臺灣熟悉的德國憲法解釋學方法論。關於美國法律主義（legalism）文獻眾多，請見Richard A. Posner, *Response, Some Realism about Judges: A Reply to Edwards and Livermore*, 59 DUKE L.J. 1177, 1177-86 (2010).

21 關於傳統解釋方法的侷限，請見Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, 20. Aufl., 1999, Rn. 56-59.

22 關於國內不同憲法解釋方法文獻，請見李念祖，昨日、今日、明日，論權力分立的憲法解釋方法——以我國釋憲之政治正確意識為觀察中心，憲政時代，41卷2期，頁179-237（2015年）。

法規定的要件，以及司法院大法官對司法院大法官審理案件法規定的解釋，以致於聲請案件不合司法院大法官審理案件法規定而被駁回？難道經過民主化以及七百多號大法官解釋，憲法的規範內容越來越不清楚，以致於大法官對於憲法規範內容產生更大的歧異，必須透過協同意見書或不同意見書來表達？

（二）政治態度模型

大法官個人政治態度方法（attitudinal approach）為美國政治學界常用的研究方法，關心的議題集中在大法官的判決是否和提名總統的意識型態有顯著關連²³。本文認為，光從大法官個人政治態度，或者某個大法官是那個總統提名難以令人滿意地回答本文的問題。難道晚近馬英九總統提名的大法官都不喜歡受理案件，只是不停地書寫分別意見書，而李登輝總統或陳水扁總統提名的大法官則特別能夠形成一致見解，不必靠分別意見書抒發個人己見？依憲法增修條文第5條，大法官交錯任命，任期互有重疊。要在個別解釋中考察大法官的政治態度並不容易。再者，我國大法官解釋，並不採美國最高法院主筆大法官制度，所有解釋都是全體出席大法官簽名。有不同意見或協同意見者再各自發表或加入。湯德宗大法官於司法院釋字第696號解釋協同意見書批評，此造成責任不清、意見不明。此種制度侷限同時構成本文考察個別大法官解釋行為時的障礙²⁴。

即便部分大法官發表分別意見書，但未發表之大法官真正意向外界無從得知，無法判定是否贊成多數意見。縱使近年來個別大法官發表分別意見書風氣鼎盛，如果要憑著有限的不同或協同意見書

²³ CORLEY ET AL., *supra* note 18, at 51-52.

²⁴ 對於司法院大法官解釋採政治態度方法研究請見 Lucia Dalla Pellegrina et al., *Judicial Ideal Points in New Democracies: The Case of Taiwan*, 7 NTU L. REV. 123, 141-65 (2012); Nuno Garoupa et al., *Explaining Constitutional Review in New Democracies: The Case of Taiwan*, 20 PAC. RIM L. & POL'Y J. 1, 1-40 (2011).

來推論大法官的解釋行為，樣本數有偏差，推論出的母體（所有大法官的司法理想點）可信度就會打折扣。譬如翁岳生大法官，甚少撰寫分別意見書，如何從有限的個別意見書推論他的解釋行為，實在大有問題。更不用說，賴浩敏大法官從未撰寫分別意見書，無從知悉其投票傾向。同樣兼任司法院院長，許宗力大法官仍舊勤於發表己見。院長個人風格不同，與提名院長人選的總統有何關連？

Sunstein在2006年的實證研究顯示，除了大法官的司法信念對於其投票行為扮演重要角色，此外判決先例、害怕其他政治部門的報復、法院內部的趨同壓力（共識壓力）等等，都會對法官的意識型態或前理解形成牽制²⁵。換言之，大法官的解釋並非個人沈思後的獨白，更不可能毫無外在制約，在真空下直接貫徹個人信念。為了更適切地說明大法官的解釋，本文需要藉助以下策略行為模型。

（三）策略行為模型

大法官的憲法解釋受到個人對憲法的前理解所影響。影響司法院大法官憲法政策選擇的因素，不是只有大法官個人的政治信念而已。不良的制度設計，會誤導大法官做白工。例如湯德宗大法官明白承認，憲法解釋的制度設計會影響大法官的行為選擇，「成功的制度設計需要結合適當的誘因。大法官解釋應改採『顯名主義』，以期循名責實，植入正向誘因（incentives）。²⁶」為了讓自己的法律信念在最大可能範圍內實現，成為多數解釋，大法官必須考慮形成多數見解的內在與外在制度因素，採行最佳策略²⁷。司法行為並非獨腳戲，個人對憲法的前理解或政治信念主要決定了個人司法行

25 CASS R. SUNSTEIN ET AL., ARE JUDGES POLITICAL?: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF FEDERAL JUDICIARY 147-48 (2006).

26 請見司法院釋字第700號解釋湯德宗大法官不同意見書。

27 LEE EPSTEIN & JACK KNIGHT, THE CHOICES JUSTICES MAKE 1-20 (1998). Lee Epstein & Tonja Jacobi, *The Strategic Analysis of Judicial Decisions*, 6 ANN. REV. L. SOC. SCI. 341, 341-58 (2010).

為的目標，這些目標同時也是個人的價值，必須考慮其他大法官的政治信念與優先價值選項，在彼此的溝通與互動中實現。最終的司法解釋乃大法官相互依賴的策略選擇結果²⁸。

大法官的策略互動受到正式和非正式的制度所制約，並非在真空中發生。正式制度主要是大法官合議制決策規則，例如誰有權聲請解釋（人民、法官或三分之一以上的立法委員），司法院大法官如何決定案件受理與否（分案大法官、三人小組、審查會），受理後是否舉辦言詞辯論，何時做成決定（時間的因素），如何通過解釋（解釋門檻），解釋的內容明確或模糊，是否容許發表分別意見書（不同意見書或協同意見書）。非正式的制度如大法官的非正式聯誼。

大法官能不能將個人信念轉換成有法拘束力的多數意見，同時繫於人民和其他憲法機關能否接受大法官的策略互動結果的正當性。固然，在憲法國家之下，所有政治權力的行使都必須符合憲法國家的權限與程序規定，才能取得支配的合法性（與正當性），透過權力符碼進行的政治溝通也離不開憲法框架²⁹。大法官解釋沒有特別的執行工具，若其他國家機關不接受大法官解釋，甚至會引發憲政危機。人民的一般性信任乃成為司法院大法官成功運作的重要支柱³⁰。因此，大法官的策略互動必須考量權力分立因素，以及能

28 請見LEE EPSTEIN ET AL., THE BEHAVIOR OF FEDERAL JUDGES: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF RATIONAL CHOICE 47 (2013). Posner等人以所謂勞動經濟學理論來解釋法官的司法行為，與本文主張的策略行為模型基本上預設相同，大法官作為「司法勞動者」，影響其決策行為因素可能包括他個人的價值（或稱意識形態）、對法的詮釋、實際的考量、對於達成其目的的策略、以及節省個人勞績費神撰寫意見書等等因素。

29 在此意義下，憲法成為法次體系與政治次體系的結構偶連（strukturelle Koppelung）制度，請參Niklas Luhmann, Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, Rechtshistorisches Journal 9 (1990), S. 176-220; ders., Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 468-481.

30 德國聯邦憲法法院長久以來擁有德國人民高度的信任，請見Hans Vorländer/André Brodacz, Das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht - Ergebnisse einer

否增進人民的一般性信任。

無論是司法院大法官的內在或外在制度條件，都是歷史時空下不斷演變的結果。有時因制度自我維持的內在惰性，形成制度轉變的障礙。主要原因在於既有制度會影響誰有權力界定議題，並主導政策的發展。其次，制度的框架會誘導行動者維護現狀、並制裁現狀挑戰者。本文固然不認為歷史遺留的制度會形成絕對不可克服的障礙，過去歷史積累所形成的制度，對於往後策略互動選項的路徑有著深淺不一的影響，描繪司法院大法官策略互動不能忽視制度演變的歷史形成因素³¹。

二、統計方法說明

本文圖表使用描述性的統計（descriptive statistics）研究方法³²，使用Microsoft Office Excel與IBM SPSS Statistics 19軟體，針對大法官解釋的解釋數量、個別大法官的分別意見書、解釋歷經時間、聲請人、有無言詞辯論、解釋門檻以及解釋合憲或違憲等項目進行編碼，期能在策略行為模式的參考架構下描述大法官在制度的

repräsentativen Bevölkerungsumfrage, in: Vorländer (Hrsg.), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, 2006, S. 259 (261).

31 Peter A. Hall & Rosemary C. R. Taylor, *Political Science and the Three New Institutionalism*, 44 POL. STUD. 936, 936-57 (1996). 列出三種新的制度主義方法論，亦即歷史制度主義（historical institutionalism）、理性抉擇制度主義（rational choice institutionalism）以及社會學制度主義（sociological institutionalism）。本文的看法比較接近溝通制度論，制度可能限制行動者的溝通選項，社會行動者的溝通也可能突破歷史制度遺留的限制，未可一概而論。請見Vivien A. Schmidt, *Taking ideas and discourse seriously: explaining change through discursive institutionalism as the fourth 'new institutionalism'*, 2(1) EUR. POL. SCI. REV. 1, 1-25 (2010); Vivien A. Schmidt, *Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse*, 11 ANN. REV. POL. SCI. 303, 303-26 (2008). Ginsburg 對於司法院大法官如何在臺灣民主化的過程中，一步一腳印地逐步擴張違憲審查正當性有生動地描述，請見TOM GINSBURG, JUDICIAL REVIEW IN NEW DEMOCRACIES: CONSTITUTIONAL COURTS IN ASIAN CASES 106-57 (2003).

32 LEE EPSTEIN & ANDREW D. MARTIN, AN INTRODUCTION TO EMPIRICAL LEGAL RESEARCH 130-38 (2014).

制約下，如何進行策略互動。以回答本文的問題，為何大法官解釋案件變少、歧異變大。

本文的研究範圍，從司法院釋字第313號解釋至司法院釋字第739號解釋³³。1993年2月修正公布「司法院大法官審理案件法」奠定往後的解釋規則，司法院釋字第313號解釋以後解釋都適用相同解釋門檻，司法院釋字第312號解釋以前解釋門檻不同，相互比較的案件相似性基礎較為薄弱，故不在比較之列³⁴。依序為每號解釋中的「聲請日期」、「解釋日期」、「聲請人」、「言詞辯論」、「協同意見書」、「不同意見書」、「合憲與否」等資料進行編碼，並使用Microsoft Office Excel以及IBM SPSS Statistics 19進行統計分析與卡方檢定。

進行SPSS分析時，本文將聲請人分類為人民、法官、立委、行政院、監察院、考試院、地方機關、總統及國民大會，若出現上述聲請人則會被編碼為1，若無則為0。有無言詞辯論、協同意見書、不同意見書等項目，有則編碼為1，無則為0。統一解釋編碼為0，合憲編碼為1、違憲編碼為2。

本文統計意見書總數的方式為協同意見書、不同意見書、部分協同部分不同意見書、部分協同意見書、部分不同意見書之總和。而協同意見書與不同意見書之數量圖，為使讀者一目了然，部分協同意見書歸類於協同意見書、部分不同意見書歸類於不同意見書、部分協同部分不同意見書歸類於協同意見書、不同意見書各一份，若A大法官提出協同（或不同）意見書，B大法官加入，也只算一份意見書。本文計算個別大法官撰寫分別意見書之統計方式為，A大法官提出，B大法官加入，則A、B大法官各算一份。

33 司法院大法官解釋網站，<http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p03.asp>（最後瀏覽日：2016年8月11日）。

34 司法院大法官審理案件法演變，詳見以下「三」說明。

本文為分析解釋時間與分別意見書之相關性，須將解釋所歷經的時間予以分類，司法院釋字第313至第739號解釋所歷經的時間最短為24天，最長2569天，分類越詳盡誤差越小，可信度越高，倘若以25天為區間，編碼超過100筆資料，製作出之圖表讀者無法一目瞭然，故本文以50天為一個區間，試圖以最詳盡、讀者最易明瞭之方式將其分類。遇併案時，聲請歷經時間之計算係以最早聲請的案件為起點。以司法院釋字第662號解釋為例，最早聲請之案件日期為97年9月9日，最後一案聲請日期為98年6月12日，解釋公布日期為98年6月19日，歷經時間即是以前者起算。

參、危機的歷史起源與轉變

憲法的主要起草者張君勱認為，違憲審查權如「運用不當，一定發生司法院的威信問題，憲法亦無法藉其解釋而穩定。³⁵」不過，司法院僅在南京做成兩號解釋，自司法院釋字第3號解釋以後，全是在臺灣實踐的結果³⁶。一般認為，臺灣在解嚴以前處於威權統治之下³⁷。有疑問的是，職司違憲審查的司法院大法官如何和威權統治併存。統治者若直接廢除司法院大法官恐怕有損冷戰時期「自由中國」的形象，違憲審查若發揮功能，勢必節制政府權力，威權統治將難以為繼。

35 張君勱，補講一 新憲法施行及培植之關鍵，自由中國之聲，2017年11月2日，<http://vfc.roonline.org/zh-hant/2017/11/02/中華民國民主憲法十講（十）/>（最後瀏覽日：2019年1月8日）。

36 請參翁岳生，大法官功能演變之探討，收於：法治國家之行政法與司法，頁418（1994年）。

37 翁岳生，我國釋憲制度之特徵與展望，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁311（1998年）；Samuel P. Huntington, *Democracy's Third Wave*, 2(2) J. DEMOCR. 12, 24-25 (1991).

司法院大法官於1948年第一次大法官會議時自行制訂「司法院大法官議事規則」，參與司法院組織法制訂的立法委員陳顧遠表示，這個議事規則是「關門主義，案子越少越好，法律上有爭議與其議事規則不合可以不理」。³⁸對照民國四十年代政治氣氛，司法院大法官「案子越少越好」主義，不失為避免與政治部門衝突的一種方法。然案件再怎麼少，還是有解釋的時候，一旦涉及政治部門的權限，便可能引發司法院大法官與政治部門的緊張。

現在的困境主要由司法院釋字第76號解釋引爆憲政機關衝突所造成。威權體制經由司法院組織法的修改，以及「司法院大法官會議法」的制訂，引進超高解釋門檻，造成解釋案件急遽萎縮，同時引進不同意見書制度，弱化司法院大法官解釋正當性。儘管隨著1986年解嚴，司法院大法官開始摸索如何在民主化與民主鞏固過程中，逐步建立自身違憲審查的權威³⁹，高門檻、分別意見書和其他制度的交互作用，儼然成為司法院大法官如今解釋案件遞減，歧異日增的重要結構因素。以下首先說明因司法院釋字第76號解釋引起政治部門反彈後，立法院制訂高解釋門檻限制解釋數量（以下「一」）以及引進分別意見書制度後，形成今日解釋歧異的歷史演變（以下「二」）。

一、高解釋門檻壓抑解釋數量

究竟哪些因素影響個別大法官決定是否受理案件，外界不得而知。依現行實務，無論宣告系爭法律違憲或合憲，都必須得到出席大法官三分之二以上多數同意。縱使認為違憲大法官未達三分之二，只要認為合憲大法官同樣未達三分之二，聲請法律違憲案件就會陷入進退兩難的僵局。除非有大法官被說服或願意妥協改變見解，或者現有大法官任滿，新任大法官改變贊成與反對的結構，法

38 立法院公報，19會期7期，頁64，陳顧遠委員發言（1957年）。

39 GINSBURG, *supra* note 31, at 106-07.

律違憲聲請案即懸而未決⁴⁰。一般認為，三分之二門檻乃限制司法院大法官產能的重要結構因素，唯有控制受理案件數量，大法官才能在有限的時間內，在高門檻下做成有限解釋。以下「(一)」說明高門檻的歷史緣由與演變；以下「(二)」和「(三)」闡述高門檻對於大法官三人小組和審查會策略互動的影響；以下「(四)」分析門檻與已解釋案件類型的關連。

(一) 司法院釋字第76號解釋的歷史陰影

1948年9月大法官自行訂定的「司法院大法官會議規則」第12條規定⁴¹「大法官會議應有大法官總額過半數之出席，出席大法官過半數之同意，始得為決議，可否同數時，取決於主席，但解釋憲法或為法律或地方自治法抵觸憲法之決議，應有大法官總額過半數之同意。」司法院釋字第76號解釋起因於國民大會、立法院與監察院爭執誰是真正的國會，從聲請書中得知，涉入爭議的關係機關都曾經請求總統行使院際調解權（憲法第44條），但總統本身無法解決兩個憲政機關的爭議，乃轉而函請大法官解決這兩項憲法疑義。1957年司法院釋字第76號解釋認為「國民大會、立法院、監察院共同相當於民主國家之國會」，結果並非皆大歡喜，反而引起當時立委普遍不滿，立法院憤而制定「司法院大法官會議法⁴²」，開始

40 詳細說明請見，許宗力，邁向2.0版的憲法訴訟程序——評新版大法官審理案件法草案，收於：台灣法學會編，台灣法學新課題（十一），頁6（2015年）。高門檻缺點，請另見鄭健才，大法官行使解釋權的程序規範，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁433（1998年）。

41 1952年大法官會議規則第12條「降低大法官會議出席決議人數，規定大法官會議開會時，須有在中央政府所在地全體大法官三分之二以上出席。如為決議，須有在中央政府所在地全體大法官過半數之同意。」請見司法院大法官網站，https://www2.judicial.gov.tw/FYDownload/p01_05.asp（最後瀏覽日：2020年7月18日）。以下詳細說明請見翁岳生，我國憲法訴訟制度之展望，中研院法學期刊，創刊號，頁1-62（2007年）。

42 請見立法委員仲肇湘等43人臨時動議「司法院解釋憲法及統一解釋法令條例草案」，立法院公報，20會期4期，頁41-44。仲肇湘等43人草案請見立法院公報，21會期19期，頁7-8。詳細說明請見涂浩如，司法院大法官會議法釋論，法學叢

「壓抑大法官之地位，限制大法官職權之行使。⁴³」其中引入高解釋門檻和不同意見書影響至今，餘波蕩漾。

為了正當化限制司法院大法官解釋權行使，立法委員喬一凡等99人提出「司法院組織法第四條條文及第五條條文草案」，發言中甚至指責「現在我們司法界還有前清和北洋軍閥的遺民遺老。⁴⁴」立法委員仲肇湘等43人提出的「司法院大法官會議法」草案則為後來限制大法官職權的主要基礎，草案第10條原本僅規定「解釋憲法或為法律或地方自治法抵觸憲法之決議，應有大法官總額三分之二之出席，出席大法官三分之二之同意。⁴⁵」不過到了立法院會二讀時，被改成釋憲和修憲一樣困難，司法院大法官會議法第3條第1項乃規定：「大法官會議解釋憲法，應有大法官總額四分之三之出席，暨出席人數四分之三之同意，方得通過。⁴⁶」「採高額絕對多數通過方式，嚴格限制釋憲案之通過。表面上係求鄭重，實際上係使大法官難以通過宣告法律違憲之釋憲案。⁴⁷」同法第3條第2項規定，大法官會議解釋憲法，「須以憲法條文有規定者為限」，造成大法官釋憲功能嚴重萎縮⁴⁸。民國47年到74年，大法官每年解釋都不到10件，甚至2或3件也很常見。第一屆到第三屆（1948-1976年）大法官只宣告一個法律違憲⁴⁹。

刊，4卷1期，頁40-41（1959年）。

43 請見楊與齡，司法規則制定權與大法官審理案件程序法規之制定及修正，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁341（1998年）。

44 請見立法院公報，19會期7期，頁57。

45 請見立法院公報，21會期19期，頁8。

46 請見立法院公報，20會期5期，頁138以下。蘇永欽，憲法裁判的評決與書寫，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，公法研究的世代對話：法治斌教授逝世十週年紀念論文集，頁15（2013年）。立法歷程請見涂浩如（註42），頁43-45。

47 請見楊與齡（註43），頁342。

48 請參考翁岳生，論行政處分，收於：法治國家之行政法與司法，頁11（1994年）。批評請見李念祖，扭曲的特別多數不是憲法訴訟的正當程序——我看「司法院大法官審理案件法」修正草案，台灣法學雜誌，222期，頁19-20（2013年）。

49 GINSBURG, *supra* note 31, at 124.

司法院大法官於1982年做成司法院釋字第175號解釋，認為「司法院……就其所掌有關司法機關之組織及司法權行使之事項，得向立法院提出法律案。」透過司法院的法案提案權，司法院大法官開始嘗試與立法院對話，提出草案突破「司法院大法官會議法」的限制，爭取對自身比較有利的互動規則。1980年司法院專案小組會議上，范魁書委員認為「大法官會議法本身即是一違憲的法律」⁵⁰，但司法院大法官終究不敢直接宣告「司法院大法官會議法」違憲。而是走迂迴前進的路線，提出草案降低解釋門檻。

1986年（解嚴前一年），司法院大法官透過非正式的聯誼強化互信（詳見下述），開始突破每年10件解釋，但仍苦於高門檻的限制。1993年2月修正公布「司法院大法官審理案件法」。司法院函送立法院大審法草案說明指出「現行條文第1項關於解釋憲法案件之可決人數規定為出席人之四分之三，較諸美、日、德、奧等國立法例，比率固高，實務上亦常以少數人堅持意見，導致案件難以審結」⁵¹。最後通過大審法第14條第1項「大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意，方得通過。但宣告命令牴觸憲法時，以出席人過半數同意行之。」大法官釋憲功能雖仍受到層層節制，命令違憲審查則已大幅放寬⁵²。受惠於大法官解釋程序法放寬管制，釋憲效率演出「噴出行情」，1993年做出21件、1994年做出37件解釋。1995年到2000年都維持在二十幾件的水準，這已經是歷來解釋案件最多產的年代。

（二）三人小組的篩選

司法院大法官做成解釋必經三人審查小組討論、審查會、大會

⁵⁰ 楊與齡（註43），頁344。

⁵¹ 請見立法院第1屆第90會期第9次會議議案關係文書，中華民國81年10月16日，頁21-22。

⁵² 楊與齡（註43），頁356以下。

三個階段⁵³。上述不同案件的解釋門檻僅適用於解釋原則及解釋草案，對於案件是否受理及解釋理由書草案文字之議決，僅需出席大法官過半數之同意⁵⁴。現有案件不受理程序需由承辦大法官註明不受理理由，並經其所屬三人審查小組之其他兩位大法官同意會簽後，再經全體大法官組成之審查會決議不受理⁵⁵。在高解釋門檻，以及複雜的受案程序限制下，基於大法官個人的理性策略選擇，最終大部分的案件都會不受理。陳新民大法官卸任後感慨「上述的嚴格—近乎嚴苛的受理門檻，無疑的暴露出我國釋憲機制功能的不彰，致使國民能藉著違憲審查機制來糾正我國法令瑕疵的『診療能量』，僅達到『聊備一格』的程度罷了。⁵⁶」

三人小組乃司法院大法官解釋「初審」，原本依「大法官會議規則」第8條之規定為一人，「司法院大法官會議法」第9條增加為三人，立法理由認為這樣比較慎重⁵⁷。依吳庚大法官經驗，「三人小組之作用不大。大法官依次輪分案件，與個人專長無關，第一階段由分到案件的大法官擬具解釋文及解釋理由書草案，與小組成員共同簽名提交審查。第二階段為全體審查會的作業，以小組提出的草案為基礎，先通過解釋原則，再就文字逐段討論，同仁之間有辯論、有詰難，字斟句酌、反覆推敲，過程慎重而緩慢，有經過三、四十次審查會始定案者，審查會通過的草案，未必就是承辦小組的

53 翁岳生，憲法之維護者——省思與期許，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（六）（上冊），頁24-28（2009年）；吳庚，憲法的解釋與適用，3版，頁361-362（2004年）；蘇彥圖（註1），頁42-43。

54 請見司法院大法官審理案件法施行細則第14條：「關於解釋原則及解釋文草案之議決，依本法第14條之規定行之。關於案件是否受理及解釋理由書草案文字之議決，以出席大法官過半數之同意行之。」

55 請見廖義男，從釋憲經驗談釋憲理論與程序，收於：憲法及行政法制，頁94（2015年）。

56 陳新民，大法官要多點人性與人道，中時電子報，2016年10月27日，<http://opinion.chinatimes.com/20161027006136-262105>（最後瀏覽日：2016年10月28日）。

57 涂浩如（註42），頁56。

原案。審查會討論的過程有如二十世紀的哲學大師海德格（Heidegger）及加達默（H. G Gadamer）所講的證釋循環。⁵⁸」

由以上吳庚大法官的敘述可以得知，大法官的審理程序（決策程序）注定曠日廢時，欲快不能。首先，案件分案與大法官個人專長無關，縱然每一個三人小組成員通常多尊重承辦大法官的意見。大法官審查會時，對於全體大法官而言，誰是承辦人一清二楚，沒有所謂保密分案問題⁵⁹。若單純依承辦大法官個人對聲請案件是否符合大審法聲請要件，決定提出是否受理的草案，必須考量三人小組擬具解釋文及解釋理由書草案被審查會推翻，甚至修改得面目全非的風險不低。

如果承辦大法官初步認定本案聲請無理由，理性的抉擇可能會誘使他寫一個聲請書不合聲請要件的草案。從解釋「勝敗」結果來看，聲請解釋不合程序要件，和合於程序要件但本案合憲，兩者是一樣的。但是審查小組提出不受理/程序駁回草案，僅需於審查報告中敘明理由⁶⁰。反之，若三人審查小組認為應該受理聲請案件，應於提出審查報告之同時，提出解釋文及解釋理由書草案⁶¹。花費更大的時間與精力研究聲請案的複雜法律關係。案件經受理後，承辦大法官草案也有淪為少數不同或協同意見的風險。更難堪的是，「釋憲實務上，承辦大法官所提受理與否之意見經評決不同意時，仍由原承辦人重提理由。⁶²」換句話說，承辦大法官必須違背自己

58 吳庚、陳淳文，憲法理論與政府體制，增訂3版，頁694（2015年）。Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode – Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 6. Aufl., 1990, S. 270-289.

59 吳庚、陳淳文（註58），頁694註78。

60 請見司法院大法官審理案件法施行細則第9條第1項：「聲請解釋案件經審查小組認應不受理者，應於審查報告中敘明理由，逕提大法官會議議決之。」

61 請見司法院大法官審理案件法施行細則第10條。

62 請見司法院「司法院大法官審理案件法修正草案條文要旨總說明及對照表」說明，頁51。司法院網站，http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p10_02.asp?id=109099（最後瀏覽日2016年10月5日）。涂浩如（註42），頁57。

的憲法確信，重寫釋憲理由書。面對制度對自身信念的折磨，恐怕承辦大法官連追求「沒有結果亢奮（sterile Aufgeregtheit）」的熱情也會消退。如果承辦大法官初步認定本案聲請無理由，而多數大法官可能會認為有理由，理性的策略選擇有可能誘使他/她提出不受理草案，縱使在審查會當中，多數大法官認為應實體受理，甚至做成本案違憲解釋，這時多數大法官要負擔說服其他大法官的負擔。在司法院大法官受案能量極度有限的情況下，要推翻承辦大法官與三人小組的不受理決定，並非易事。

如果承辦大法官初步認定本案聲請有理由，例如某些大法官可能認為死刑違憲，他/她還是得考量多數大法官是否會和他/她採相同見解。如果預期個人見解可能淪為少數不同或協同意見，一旦貿然提出受理，很有可能在三人小組就受到阻力，「遇有重大疑難的案件，小組內部也會熱烈討論。⁶³」縱然小組形成共識，還得經過審查會這關。審查會很有可能不願受理，承辦大法官嘔心泣血撰寫的意見還是如落花流水。若審查會決定受理，也是苦事一件。他/她提出的意見只能以不同意見形式呈現，反對意見（例如死刑合憲）則成為多數意見。因此，承辦大法官比較好的策略選擇是提出防衛性不受理草案⁶⁴，縱使在審查會當中，多數大法官認為應實體受理，甚至做成本案合憲解釋，這時多數大法官要負擔說服其他大法官的負擔，若涉及法律合憲解釋，承辦大法官反而可以利用三分之二的高門檻行使少數否決權。基於司法院大法官受案能量極度有限，若無明顯超過三分之二多數大法官贊成，要推翻承辦大法官與三人小組的不受理決定，並非易事。

⁶³ 吳庚、陳淳文（註58），頁694註78。

⁶⁴ 美國大法官如果覺得他的意見不會是多數，為了阻止反對意見成為最高法院的判決先例，也會傾向於提出防衛性不受理（defensive denial），EPSTEIN & KNIGHT, *supra* note 27, at 79-80.

（三）審查會的策略選擇

依照大審法第14條規定，司法院大法官審理案件的可決門檻分為三類⁶⁵，第一種是統一解釋憲法或法律是否違憲，需有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人三分之二同意。第二類是解釋命令是否違憲，需有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人二分之一同意。第三類則為統一解釋法律及命令，應有大法官現有總額過半數之出席，及出席人數過半數之同意⁶⁶。

在全體大法官組成之審查會討論決議受理或不受理時，如果個別大法官無法相當程度確信，其他大法官會採取和他相同見解，甚至和他採取相反見解，為了阻止和他相反的見解成為司法院大法官多數解釋，現有制度會誘使大法官在策略上採取不受理⁶⁷。對於初步認為現有法律、命令或其他爭議國家行為不違憲的大法官而言，縱使人數已經超過三分之二，在程序上將案件駁回，與實質上駁回效果無異，卻可以節省日後冗場辯論⁶⁸。再者，程序駁回可以避免反對現行法律、命令或其他爭議國家行為者透過違憲審查進行議題設定，引起社會矚目。就這兩點而言，系爭案件的決議門檻是三分

65 如前所述，司法院釋字第312號解釋以前解釋門檻更高，無法與現行制度作比較。

66 請參大審法第14條規定：「大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人三分之二同意，方得通過。但宣告命令牴觸憲法時，以出席人過半數同意行之。大法官統一解釋法律及命令，應有大法官現有總額過半數之出席，及出席人數過半數之同意，方得通過。」

67 本文的理論假設與研究美國最高法院受理案件越來越少的理論與實證研究說明相同，請參考Kenneth W. Moffett et al., *Strategic Behavior and Variation in the Supreme Court's Caseload Over Time*, 37 JUST. SYS. J. 20, 20-38 (2016). Kenneth W. Moffett, Charles Shipan & Forrest Maltzman, *The Supreme Court Is Taking Far Fewer Cases than Usual. Here's Why*, THE WASHINGTON POST (June 2, 2016), <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/06/02/the-supreme-court-is-taking-far-fewer-cases-than-usual-heres-why/>.

68 美國聯邦法官不寫不同意見書有諸多理由，未必是同意多數意見，可能是基於同儕趨同壓力，也可能是個人並不是那麼反對，寫不同意見書又耗費心神而放棄。請見EPSTEIN ET AL., *supra* note 28, at 47.

之二或二分之一，並無差別。

如圖2所示，第一類案件的決議門檻為三分之二，如果認為現有法律、或爭議國家行為不違憲的大法官超過出席半數，卻未達三分之二，駁回聲請是個比較省時省力的決定，一旦受理就必須妥協，卻未必符合其對系爭案件的個人見解。無論就節省勞力、時間和費用來看，或者是案件「勝敗」結果與大法官個人的法律信念是否一致來看，程序上駁回是較好的抉擇。反之，如果認為現有法律、或爭議國家行為違憲的大法官超過出席半數，卻未達三分之二（第8種情況），面對此種不確定的狀態，若僅考慮勞力、時間和費用，駁回還是較理性的抉擇。

若遇到第二類案件，需有大法官現有總額三分之二之出席，及出席人二分之一同意，才能解釋命令是否違憲。在圖2、情況11，多數大法官認為系爭命令合憲，經審查會實質討論後，將直接以「欠缺具體違憲的指摘」為理由，程序上駁回，不會受理後做成一個合憲解釋。例如司法院大法官第1392次會議（2012年7月27日）共不受理25案，其中18案以「欠缺具體違憲的指摘」為由駁回。當中第14案不受理，申請人桃園地方法院法官錢建榮認為，最高法院判例及決議解釋刑法第321條第1項第3款攜帶兇器竊盜罪，僅以凶器客觀上是不是具有危險性為判斷標準，而不管行為人「主觀上是否有兇器之認識，且有用以危害他人之意思」，系爭判例與決議違憲。司法院大法官駁回的理由就是「欠缺具體違憲的指摘」。立法委員李貴敏認為這根本是「採實質上的實審，但表面上是以形式上的不受理而予駁回⁶⁹。」由於「不合程序不予受理者，可說是經與受理解釋者基本上同一的程序⁷⁰」，耗費大法官相當的時間與精

69 請見立法院公報，102期4卷委員會紀錄，頁70（2013年）。

70 許宗力，大法官釋憲權行使的程序及範圍——從大法官審理案件法與修正草案之檢視談起，收於：憲法與法治國行政，2版，頁107（2006年）。

力，造成陳新民、陳敏、陳春生、黃茂榮等四位大法官八年任期內僅受理90件案件。縱使「好幾件被程序性駁回的不受理案件，其實討論的強度不輸實質審理的釋憲案⁷¹。」在外界看來，這只是茶壺裡的風暴，船過水無痕。

若考慮到案件結果是否與大法官個人的法律信念一致，多數大法官也可能決議受理第一類案件。縱使日後需面對冗長的討論與妥協⁷²，三分之二的門檻保障少數否決權，若其堅持個人信念到底，將合議的精神與價值放在比較後面，受理後持不同意見大法官必須妥協容納其意見。倘若無法達成共識或妥協，頂多受理的案件就成為死案，結果不會比從程序上就駁回糟糕。這類案件需要很多的協商與妥協，越是具有爭議的案件，審理期間就越久。下述司法院釋字第644號解釋，以及司法院釋字第718號解釋宣告緊急性集會或偶發性集會事前許可制違憲，從提出申請到做成解釋歷時1281日⁷³，可能都屬於這種狀況。因此第8種案件情況發生機率不低。

71 陳春生大法官退職感言，請見屆退大法官陳新民：每年只釋憲10件令人遺憾，自由時報，2016年10月28日，<http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1870199>（最後瀏覽日：2016年10月29日）。

72 吳庚大法官表示，依其經驗有的案件需要經過三、四十次審查會才能定案。請見吳庚（註53），頁361。

73 進一步分析，請見蘇彥圖（註1），頁34。

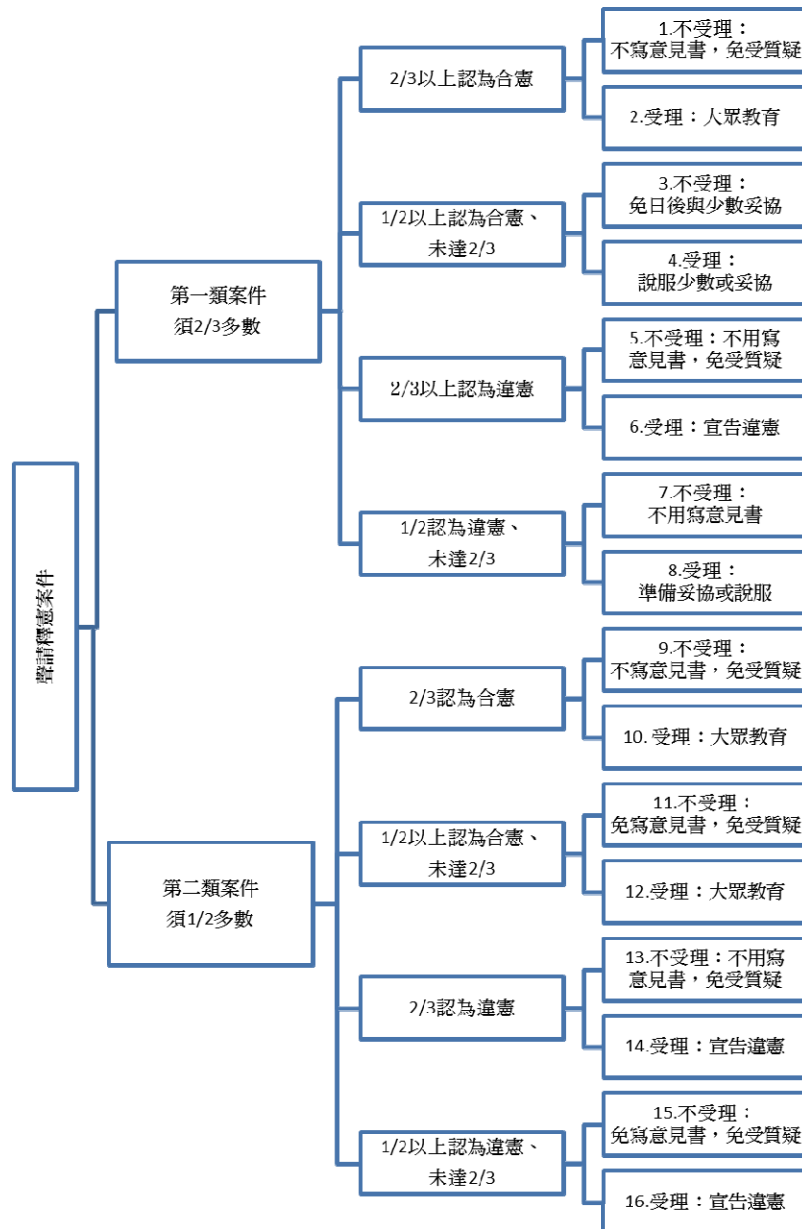


圖2 解釋門檻與防衛性不受理關係

資料來源：作者自製。

（四）門檻與已解釋案件類型的關連

本文以上說明，司法院大法官做成法律或命令違憲解釋門檻不同，會誘使大法官不受理。接著我們要問，這樣的結構差異是否會誘使大法官逃向命令違憲或命令統一解釋、不同案件類型所需解釋時間是否不同、是否會影響案件合憲或違憲？

從統計分析來看，司法院大法官統一解釋憲法或解釋法律是否違憲（第一類）總數205件，解釋命令是否違憲（第二類）總數211件，統一解釋法律及命令（第三類）的總數僅有36件。整體而言，司法院大法官並未柿子挑軟的吃，第二類加第三類僅需二分之一以上同意便可做成解釋的案件總數，並未明顯高於第一類需大法官出席人三分之二同意案件。

司法院釋字第691號至第706號解釋當中，大法官受理的案件超過一半以上都涉及行政規範審查，有8件僅涉及行政令函解釋，1件僅涉及行政規則，引發學界疑慮⁷⁴。大法官湯德宗在司法院釋字第713號解釋部分不同意見書質疑「職司憲法解釋的司法院，何時竟成了財稅法院？」或許這些批評奏效⁷⁵，整體來看，從司法院釋字第682號到第739號解釋的案件分類，並未出現大法官逃向命令違憲或命令統一解釋⁷⁶。這時期司法院大法官做出第一類共33件，第二類共27件，第三類則有5件。

⁷⁴ 黃丞儀，依法行政的悖亂政治，蘋果日報，2012年12月29日，<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20121229/34737556/>（最後瀏覽日：2016年8月2日）。

⁷⁵ 蘇永欽大法官兼司法院副院長在2013年年初演講，一開頭即注意此批評，請見蘇永欽，部門憲法的基本思維——一個在職大法官心所謂危的自剖，台灣法學雜誌，226期，頁90（2013年）。

⁷⁶ 許宗力對2013年大法官解釋的觀察得到相同結論，請見許宗力（註11），頁1041（2014年）。

為何不同解釋門檻竟然導致大抵相同的受理案件比例，也可以由大審法的門檻結構得到解答。無論是哪一類的案件，決定司法院大法官是否受理案件的門檻都一樣是出席大法官過半數，所以不同案件類型不受理的誘因基本上相同。受理的誘因可以從比較前述圖2第8種與第15種及16種情況來分析。前面的分析已經說明，第一類是統一解釋憲法或法律是否違憲，雖需雙重三分之二門檻，縱使認為現有法律、或爭議國家行為違憲的大法官超過出席半數，卻未達三分之二，由於無論是否合憲都要有三分之二才能做出，二分之一多數只要抱著願意妥協，並非全無動機受理案件。

案件受理後，本文發現解釋門檻與解釋歷經時間的關連並不顯著，亦即司法院大法官在進行第一類、第二類或第三類解釋所需花費的時間，並無顯著不同⁷⁷（請見圖3）。再者，第一類與第二類案件不同解釋門檻與司法院大法官是否宣告違憲也沒有關連（請見圖4）。本文推測，這些現象可能與三分之二高門檻強化了少數大法官的否決權，不只影響第一類案件的運作，並且外溢到第二、三類案件。個別大法官想要實現自己的理念，需要其他大法官認同，尤其高門檻要求必須尊重少數大法官意見，否則將一事無成。自2003年以後，大法官不分屆別，不得連任。對於培養大法官的集體情感或有影響，但主要表現為受理案件減少、以及分別意見書的增加⁷⁸，短暫逃向命令審查的策略行動，也因公眾批評而停止。整體而言，大法官縱使遇到前述第十四類案件，二分之一以上，不足三分之二多數大法官認為系爭命令違憲，受理後也不能不管其他少數大法官的意見，如果強勢表決，改天遇到第八類統一解釋憲法或法律是否違憲案件，要爭取這些不受尊重少數大法官的認同難度會提高。

77 第二類與第三類解釋的出席門檻雖有不同，但決議門檻相同，故本文在統計決議門檻與時間的關連性時，將兩者合併計算。

78 請見翁岳生，法律作為一種志業，世新法學，9卷2期，頁12（2016年）。

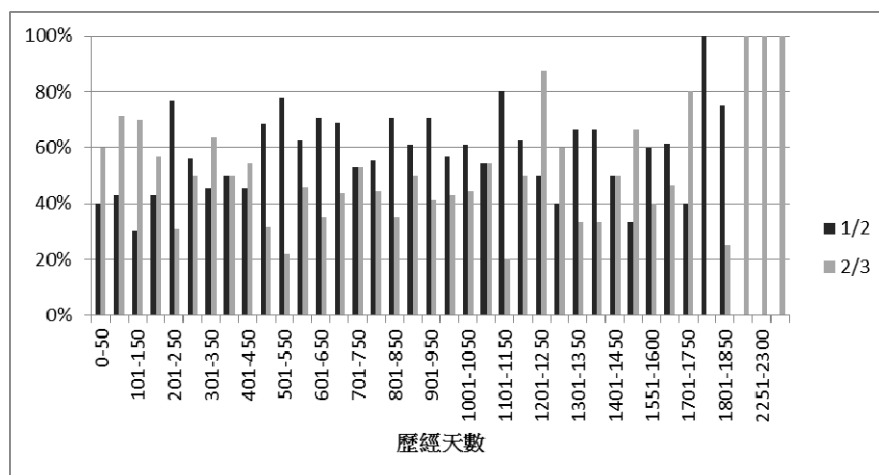


圖3 可決人數與歷經天數交叉分析

資料來源：作者自製。

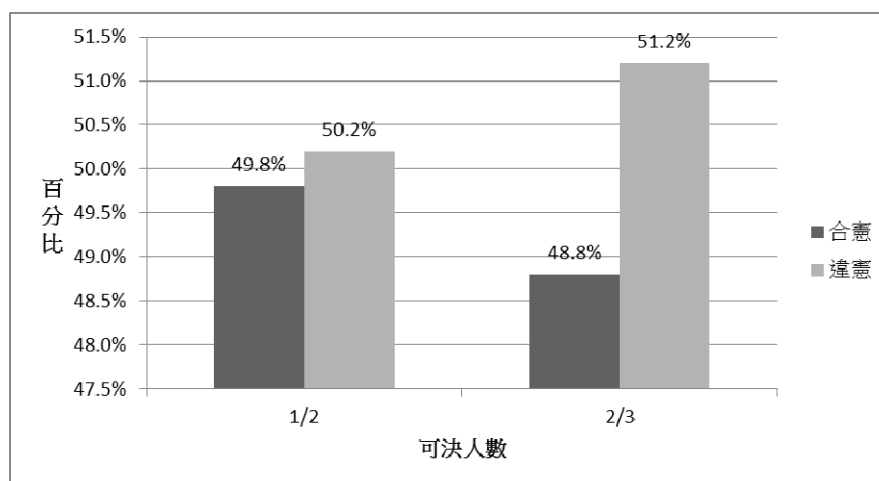


圖4 解釋門檻與是否違憲關聯性

資料來源：作者自製。

（五）解釋案件少違憲比例高

從1993到2010年總共受理372件，平均每年20.67件，平均每年9件受理案件違憲，佔受理案件的43.5%⁷⁹。從2011年迄2016年8月，總共受理56件，平均每年9.33件，平均每年5.67件受理案件違憲，佔受理案件的60.7%⁸⁰。吳庚大法官2005年認為，司法院大法官「第五屆（民國74年）起到91年止經宣告違憲的法律及命令約佔全部釋憲案的25%，比例之高，各國殆無出其右者⁸¹」。本文統計發現，大法官受理案件不斷變少，受理後宣告違憲的比例卻不斷攀高。從1993年到2010年，司法院大法官總共做成80件法律或其他國家行為違憲的解釋，平均每年約4.44件。宣告83件命令違憲，每年約4.61件。兩者加總，共做成162件⁸²違憲宣告，平均每年9件。這18年間司法院大法官共做成372號解釋，案件違憲比例為43.5%。2011年以後，共做成18件法律或其他國家行為違憲解釋，平均每年3件。

2011年到2016年8月之間，司法院大法官平均每年宣告法律或其他國家行為違憲的案件數量只有1993年至2010年的67.5%（3除以4.44）。2011年以後，共做成19件命令違憲解釋，平均每年3.2件。從趨勢上看，2011年到2016年8月之間，司法院大法官平均每年宣告命令違憲的量只有1993年至2010年的69.4%（3.2除以4.61）。2011年以後迄今，共做成34件違憲宣告，平均每年5.67件⁸³。2011年以後迄2016年8月（司法院釋字第739號解釋）為止，司法院大法

79 1993-2010年，解釋有372件，違憲的有162件， $162/372=43.5\%$ 。

80 2011-2016年，解釋56件，違憲34件， $34/56=60.7\%$ 。

81 吳庚，社會變遷與憲法解釋，收於：湯德宗編，憲法解釋之理論與實務（四），頁5（2005年）。

82 1993-2010年期間，本文將違憲分為法律違憲、命令違憲，加總後為163件，扣除既有法律違憲、且命令違憲重複計算1件，實際上違憲案件共162件，平均每年9件。

83 $34\div6=5.67\%$ 。

官平均每年宣告違憲的案件量只有1993年至2010年的62.6%⁸⁴。這6年間司法院大法官共做成56號解釋，案件違憲比例為60.7%，相較於1993年到2010年的案件違憲比例43.5%，後者違憲比例為前者的1.4倍⁸⁵。換句話說，1993年至2010年和2011年迄今兩相比較，每年平均受理案件量以及解釋違憲案件量減少，但受理案件違憲比例增加。足見2011年以後大法官更加傾向於不受理合憲案件，而一旦受理，宣告違憲的可能性則大幅增加⁸⁶（請見圖5）。

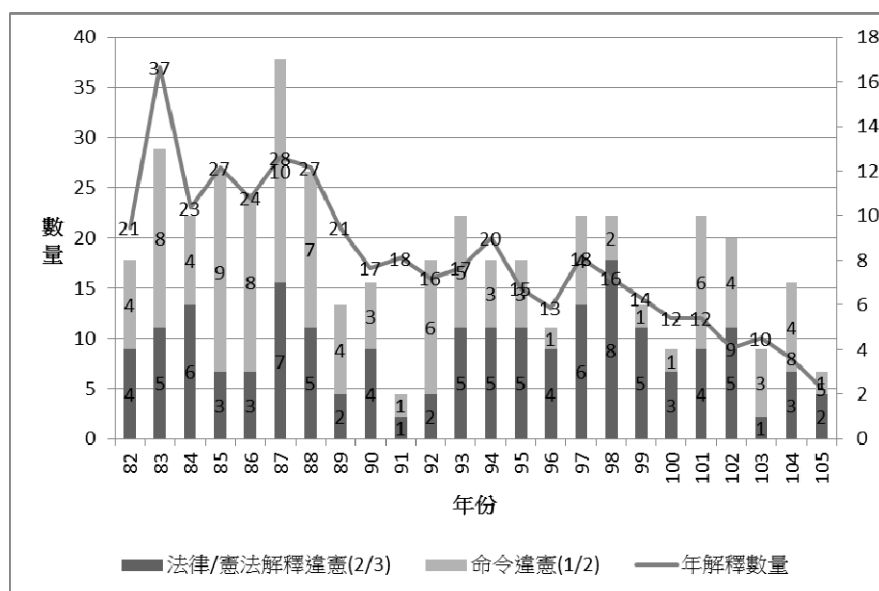


圖5 年解釋數量與違憲案件比較圖

資料來源：作者自製。

84 5.67除以9=62.6%。

85 60.7%除以43.5%=1.4。

86 較早的違憲案件比例統計，請見Jau-Yuan Hwang, *Taiwan's Constitutional Court from 2003 to 2011: New Appointments and Different Performance*, 53(2) SEOUL L.J. 41, 47 (2012).

以上統計數字與現任或前任大法官的觀察一致。大法官司法院大法官2013年僅作成9件解釋（司法院釋字第708號至第716號解釋），其中8件屬於違憲或部分違憲。許宗力大法官認為，這「代表的意義極可能是，大法官受理、選案極其嚴苛，以為可能做成違憲宣告的聲請案才有受理價值，而不輕易受理顯然合憲，或比較不可能違憲的聲請案」⁸⁷。前大法官蘇永欽也表示，2011年和2012年司法院大法官皆只做成12件解釋，「選擇性相對提高，合憲解釋更顯得意義不大，以致解釋與否越來越不是決定於爭議的憲政意義，而在能不能挑出憲法瑕疵」⁸⁸。兩位大法官的觀察支持本文圖2的觀察，大法官在有限的解釋能量下，有超前部署的策略考量，一旦在受理案件討論中發現，多數大法官傾向於系爭案件合憲，司法院大法官會採取「防衛性否決」，直接不受理案件，而非受理後宣告合憲。

以2015年為例，總共做成8件解釋，高達6件違憲⁸⁹。解釋案件違憲比例高達75%。司法院大法官受理案件越來越少，和其做成合憲解釋案件越來越少有關，有些案件大法官傾向於程序駁回取代實質受理然後宣告合憲。這種趨勢在2015年更加明顯，也造成大法官是否發表分別意見書陷入兩難困境。縱使個別大法官對8件解釋都發表分別意見書，也只有8次機會，若寫好的分別意見書一半留中不發，統計上一年頂多只有4次以個人名義撰寫意見書。因此我們可以看到，從2011年迄2016年7月近六年當中，平均每年有67份分別意見書，也就是說平均每個解釋案件有7個分別意見書⁹⁰。

87 請見許宗力（註11），頁1036。

88 蘇永欽（註75），頁91。

89 本文統計時雖顯現為，法律違憲3件、命令違憲4件，但司法院釋字第732號解釋包含解釋法律部份受理違憲、其餘不受理，解釋命令/判例/函釋部份受理違憲、其餘不受理，故實際加總後為6件違憲。

90 $402（分別意見書） \div 56（解釋案件） = 7.18$ 。

美國前大法官Felix Frankfurter曾表示：「法院的意見僅僅揭露司法程序的表象。一個意見可能包含許多妥協，代表許多集體努力。許多晦暗不明的考慮可能影響案件的最終結果，達成最終判決前可能有許多人改變立場，我們無法在所有案件中同時把所有這些以及其他因素表現出來。⁹¹」我國大法官的解釋應該也是「一言難盡」。不過，我國制度造成解釋量難以發揮。個別大法官若不發表分別意見書，可能被外界解讀為無聲大法官⁹²，這可能間接導致碩果僅存的少數解釋案例成為大法官們華山論劍競技場。固然難有共同標準決定解釋品質與解釋數量之間的關係。分別意見書多未必等於好，少也不見得等於差。迄今也沒有標準可以決定，什麼是「最適」分別意見書發表量。只要個別大法官在有限的解釋中發表分別意見書，統計上就會呈現百花齊放的景觀。

二、分別意見書的作用

以上描述圖像可以由大法官在制度中策略互動的演變歷史得到初步理解。司法院釋字第76號解釋造成1958年大法官會議法制訂，同時引進不同意見書，其政治動機在於弱化司法院大法官解釋正當性。往後從不同意見書分化出「理由不同意見書」與「協同意見書」，此制度改變有利於大法官解釋跨越門檻（以下「（一）」）。2000年以後不同意見書和協同意見書之間比例的轉變，和司法院大法官本身合議制運作的轉變，以及大法官任期制度的改變有關連（以下「（二）」）。統一解釋憲法或解釋法律是否違憲案件妥協性較

91 Felix Frankfurter, "The Administrative Side" of Chief Justice Hughes, 63 HARV. L. REV. 1, 1 (1949).

92 美國最高法院大法官Thomas每年大約主筆8個最高法院判決。2016年以前，Thomas大法官曾經維持10年內不曾在最高法院言詞辯論中發問的紀錄，2016年首度發問，被紐約時報專文報導「Clarence Thomas大法官打破在最高法院的10年沈默。」Adam Liptak, *Clarence Thomas Breaks 10 Years of Silence at Supreme Court*, THE NEW YORK TIMES (Feb. 29, 2016), <https://www.nytimes.com/2016/03/01/us/politics/supreme-court-clarence-thomas.html>.

大，大法官撰寫協同意見書的比例較高（以下「(三)」）。和美國與德國相較，大法官解釋分別意見書較多，分歧較大，甚至可能動搖其解釋正當性（以下「(四)」）。

（一）分別意見書的引進與轉變

司法院大法官解釋一開始只有解釋文，沒有解釋理由書。1948年9月15日通過的司法院大法官會議規則第20條僅規定「大法官之解釋，經決議後，由司法院公佈，並通知原機關。」大法官對於解釋文有沒有歧見，外界不得而知⁹³。論者批評大法官會議法「過份注重大法官會議權限制」⁹⁴，不僅限制大法官必須四分之三以上人數高門檻才能通過憲法解釋，引進不同意見書具有制止多數意見「隨隨便便決議」的功能。司法院大法官會議法第17條規定「大法官會議決議之解釋文，應附具解釋理由書，連同各大法官對該解釋之不同意見書，一併由司法院公布之，並通知本案聲請人及其關係人⁹⁵」。本條規定在立法院辯論時，立法委員鄧工的發言頗具代表性，他認為：

（司法院釋字第76號解釋）空洞地表示「國民大會、立監兩院共同相當於民主國家之國會」，這樣的相當，相當於哪一國的國會？何以又共同相當？凡此理由均未予以說明，像這樣的解釋我們認為很不妥當，同時由國會的解釋，我們也知道有少數是不同意的，但究竟哪幾個大法官有不同的意見，我們也不知道。因此這次制定大法官會議法便採用美國的方法，不但要大法官公布決議案，而且要將決議案的理由予以詳細發表，不但多數的意見要發表，而少數的

⁹³ 劉鐵錚，大法官會議不同意見書之理論與實際，頁18-19（2003年）。

⁹⁴ 翁岳生，憲法之維護者，收於：行政法與現代法治國家，頁476（1976年）。

⁹⁵ 司法院大法官網站，<https://law.judicial.gov.tw/FLAW/hisdata.aspx?lsid=FL000849&ldate=19580721&lser=001&ot=in>（最後瀏覽日：2020年5月31日）。

意見也主張予以公布。如此此後大法官解釋法律時，當然就不能隨隨便便下一個決議就算了，這對國民法律教育也是很有價值的⁹⁶。

立法委員趙家焯則擔心公布不同意見，大法官個人必須承擔政治部門的壓力，會造成大法官不敢暢所欲言。他表示：

（只）公布多數通過的意見，並不是說多數的意見不見得好，而少數的意見特別好，恐怕國人看到少數人比多數人強，多數人很難為情的關係，因為我們是民主國家當然要少數服從多數的意見，少數人的意見怎麼樣好，沒有通過，還是沒有用。……大法官所發表的不同意見對外負不負責任呢？一旦公布說話就有顧忌，以致在會議中不能暢所欲言⁹⁷。

趙家焯刪除一併公布不同意見的看法，並未為司法院大法官會議法所採。因此，主流的意見認為「不同意見書或協同意見書究係基於大法官地位所發表之意見，且由司法院公佈，應屬於一種公文書。⁹⁸」趙家焯委員的意見反映在1958年10月3日制訂公布的司法院大法官會議法施行細則，其中第7條規定「大法官對於解釋文草案有不同意見者，應於大法官全體審查會議通過後五日內補具理由書敘述要點，以便與解釋文一併公布，如不於五日內補提書面者，其口頭意見視為放棄。前項一併發表之不同意見書，僅記名其不同意見之人數。⁹⁹」既然不同意見僅發表人數而不具名，少數大法官得以暢所欲言，無須忌憚輿論或其他政治壓力，間接壓縮達成四分之三憲法解釋門檻的空間。再加上僅有不同意見書，而無協同意見

96 立法院公報，21會期17期，頁18。

97 立法院公報，21會期17期，頁21。

98 劉鐵錚，不同意見書之研究，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁399（1998年）。

99 劉鐵錚（註93），頁21。

書之規定，雖同意（多數）大法官解釋結論，但不同意其理由者，也被算成是不同意見。大法官解釋的理由並非無拘束力，持協同意見者只有兩種選擇，要不勉為其難同意解釋理由，默不吭聲，要不就是表達（理由）不同意見，增加達成四分之三憲法解釋門檻的難度。一如立法院宏觀調控的預期，司法院大法官會議法實施後，大法官解釋案件大量萎縮，1952年到1957年間，平均每年解釋13件。1958年到1987年解嚴之前總共三十年，大法官僅作成141件，平均一年不到5件（請見圖1）。而在這有限的解釋當中，解釋含有不同意見書和協同意見書的比例也相當高。

外界只知有不同意見書，卻不知那位/些大法官持不同意見，本來要保護持不同意見者免受壓力或攻擊，但「外界可能猜來猜去，其他的大法官就可能受到了連累¹⁰⁰」，這樣的制度造成持不同意見者可能成為集體行動的搭便車者（free rider）¹⁰¹，可以盡情在內部表示反對意見，無須面對外界的檢驗。第四屆大法官於1976年12月14日做成司法院釋字第147號解釋，多數意見認為「夫納妾，違反夫妻互負之貞操義務，在是項行為終止以前，妻主張不履行同居義務，即有民法第1001條但書之正當理由」，有三個大法官持不同意見，前兩個不同意見書其實是理由不同意見書，分別主張夫納妾，則妻可「請求別居」。第三位大法官則是反對多數意見，主張「『夫納妾，違反夫妻互負之貞操義務』，於法似無依據」。因不公布三位不同意見書大法官姓名，其他大法官可能受到連累，於是大法官於1977年1月11日修改大法官會議法施行細則第17條，規定不同意見書隨同解釋文公布，並應公布不同意見者之姓名。第一件公布不同意見書大法官姓名的是1977年6月17日公布之司法院釋字第149

¹⁰⁰ 翁岳生，論司法院大法官會議之功能，收於：法治國家之行政法與司法，頁359（1994年）。

¹⁰¹ MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION: PUBLIC GOODS AND THE THEORY OF GROUPS 132-35 (1965).

號解釋。1999年12月15日檔案法公佈施行，自司法院釋字第80號解釋以來的不同意見書，也一併公諸於世¹⁰²，現在司法院網站上即可查閱釋字第147號解釋三個不同意見書。

第五屆大法官1985年就職後，1986年解嚴。司法院大法官也開始追尋憲政民主體制中違憲審查的新定位。縱然一時無法改變司法院大法官會議法的四分之三門檻規定，透過大法官會議法施行細則對於不同意見書的界定，也具有實質減輕門檻限制的作用。司法院於1987年8月28日修正發佈司法院大法官會議法施行細則，其中第7條第2項修正為「大法官贊成解釋文草案原則，而對其理由有不同之法律上意見者，得提出理由不同意見書。」一改過去將協同意見書算入不同意見人數的作法，此後提出理由不同意見書之大法官仍被視為贊成多數意見，不再影響是否通過多數意見的門檻¹⁰³。自1987年至1993年解釋數量有顯著增加，平均一年做成將近17件¹⁰⁴，解釋中未含不同或協同（理由不同）意見書的比例約55%，並未明顯增加。

1993年2月修正公布的「司法院大法官審理案件法」第14條第1項規定：「大法官解釋憲法，應有大法官現有總額三分之二出席，及出席人三分之二同意，方得通過。但宣告命令牴觸憲法時，以出席人過半數同意行之。」大法官釋憲功能雖仍受到層層節制，命令違憲審查則已大幅放寬。受惠於大法官解釋程序法解除管制，大法官的解釋案件大幅增加（詳見以上「一、（一）」說明）。大審法並且將之前的理由不同意見書正名為協同意見書，其中第17條規定：「大法官決議之解釋文，應附具解釋理由書，連同各大法官對該解釋之協同意見書或不同意見書，一併由司法院公布之，並通知本案

102 翁岳生（註53），頁46-47；翁岳生（註10），頁12。

103 劉鐵錚（註98），頁392。

104 1987~1993年七年間計有121號解釋。121/7=17.3。

聲請人及其關係人。」依立法說明，本條新增協同意見書一併公布「俾使各大法官對於解釋文及解釋理由書之意見得以充分公開明確表達。¹⁰⁵」

1993年5月8日司法院修正公布之司法院大法官審理案件法施行細則第18條進一步規定：「大法官贊成解釋文草案之原則，而對其理由有補充或不同之法律意見者，得提出協同意見書（第1項）。大法官對於解釋文草案之原則，曾表示不同之法律意見者，得提出一部或全部之不同意見書（第2項）。前二項意見書，應於解釋文草案及解釋理由書草案經大法官全體審查會議審查通過後五日內提出（第3項）。」1994到1999年平均每年做成將近28件解釋，具有共識的解釋，亦即未含不同或協同意見書的比例約49%，略為降低。

2000年第一次政黨輪替以後，解釋案件數量逐漸減少，不同意見書和協同意見書日漸增加。從2000年到2007年平均每年解釋17.1件。具有共識的解釋，亦即未含不同或協同（理由不同）意見書的比例約45.5%，進一步降低。尤其2004年適逢總統大選，當年共做成17件解釋，有共識的僅有3件，佔18%。2008年第二次政黨輪替，解釋案件量再度銳減，2008-2015年平均每年解釋12.38件，2011-2015年平均每年只有解釋10.2件，2015年只有做成8號解釋。迄2016年7月為止，僅作成5號解釋（司法院解釋第735號至739號）。具有共識的解釋，2008年即銳減為28%，2009和2010年都只有一件解釋未含不同或協同意見書，分別佔6%和7%。2011年之後大法官百家爭鳴成為常態，沒有一號解釋沒有不同或協同意見書（請見圖1）。解釋案件逐漸減少和分別意見書的增長有所關連。許宗力大法官認為，以2013年為例，大法官勉強找出公約數做成多數

¹⁰⁵ 司法院函送立法院「司法院大法官會議法部分條文修正草案」說明，立法院第1屆第90會期第9次會議議案關係文書，頁27（1992年）。

意見，解釋數量變少後，大法官有更充裕時間撰寫分別意見書¹⁰⁶。

（二）不同意見書和協同意見書的比例轉變

不同意見書和協同意見書之間比例的轉變，和司法院大法官本身合議制運作的轉變，以及大法官任期制度的改變有關連。2000年之前不同意見書的數量都高於協同意見書，2000年之後協同意見書的數量則一直高於不同意見書（請見圖6、圖7）。2000年做成21號解釋，協同意見書和不同意見書加起來總共15份。2015年協同意見書和不同意見書加起來達到63份。協同意見書的增長尤其驚人，2000年協同意見書只有8份，2014年則達到56份。2015年則有50份協同意見書。因解釋案件變少，大法官有壓力發表個別意見，縱使沒有不同意見，也要發表協同意見。同時，因大法官的合議制精神轉淡（詳下述），發表協同意見既不像不同意見那麼不合作，又可凸顯個人的釋憲意見。

¹⁰⁶ 許宗力（註11），頁1039-1040。

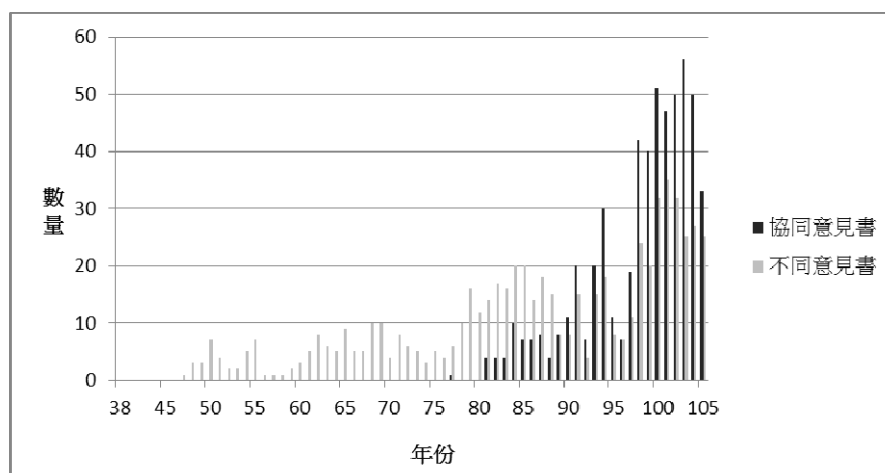


圖6 協同與不同意見書數量圖

資料來源：作者自製。

此表製作方式如下：

部分協同意見書歸類於→協同意見書

部分不同意見書歸類於→不同意見書

部分協同部分不同意見書歸類於→協同意見書、不同意見書各一份

A大法官提出協同（或不同）意見書，B大法官加入，算一份¹⁰⁷

107 類似算法，請見蘇永欽（註75），頁91。

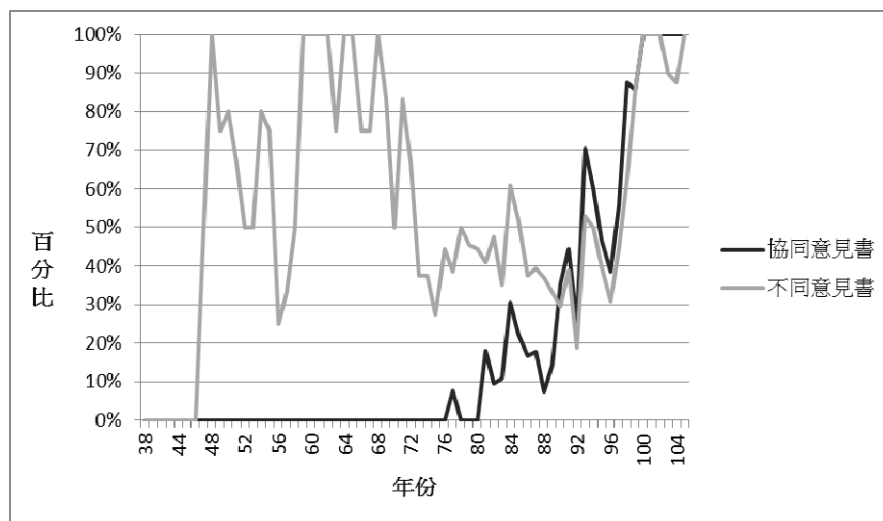


圖7 協同與不同意見書百分比

資料來源：作者自製。

(三) 分別意見書與解釋門檻

司法院大法官統一解釋憲法或解釋法律是否違憲（第一類）案件，出現協同意見書的比例顯著較高，全部的案件出現協同意見書的比例為41.9%，而第一類解釋出現協同意見書的比例為48.3%。反之，司法院大法官解釋命令是否違憲（第二類）案件，出現協同意見書的比例顯著較低，僅有34.1%。第一類、第二類、及第三類（統一解釋法律及命令）解釋不同意見出現的機率分別為54.1%、47.4%、和58.3%，和解釋門檻進行關連性分析後，皆無明顯關連（圖8）。

以上統計所呈現的圖像必須由大法官的策略互動行為來理解。本文統計完全以形式上大法官個人標示為協同或不同意見為準。如下所述，大法官面對第一類案件，需要比較大的妥協才能做出解釋。因此多數意見解釋呈現為模糊或自相矛盾，不在少數。反之，

「實質上」為反對意見，達成妥協後，為了表明個人真正意見，形式上不能標示為不同意見，而只能標示為協同意見。因此，本文統計呈現第一類案件出現「形式上」協同意見較多，但某些案件的協同意見讀起來卻像是不同意見。反之，「形式上」不同意見書出現的比例並無不同。

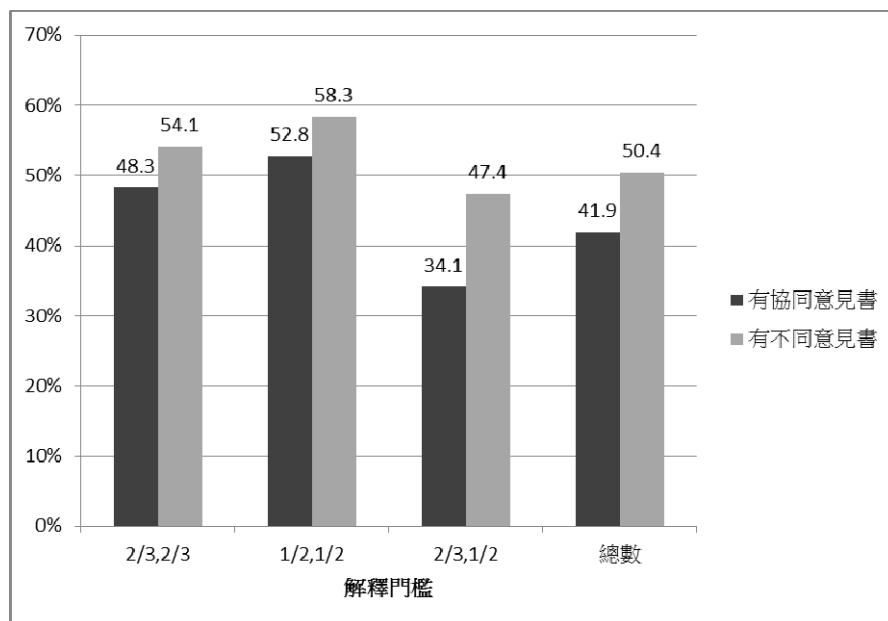


圖8 解釋門檻與意見書交叉分析

資料來源：作者自製。

(四) 分歧與解釋正當性

和美國與德國比較後發現，司法院大法官解釋日減、分歧日增乃吾國特有現象。美國對不同意見的正、負功能多有闡述¹⁰⁸，例如

¹⁰⁸ 請詳見Cass R. Sunstein, *Unanimity and Disagreement on the Supreme Court*, 100 CORNELL L. REV. 769, 802-04 (2015).

不同意見書可以增進多數意見改善並且澄清原來的判決初稿¹⁰⁹。美國最高法院自John Marshall擔任首席大法官後，崇尚法院單一意見，避免不同意見弱化法院判決的正當性¹¹⁰，直到1941年以前，美國最高法院有所謂共識規範（the norm of consensus）¹¹¹的不成文法則，不同意見書比例很少高於10%，一直到上個世紀二、三零年代，法律惟實論（legal realism）出現，這一不成文法才被打破¹¹²。在共識規範下，美國大法官Louis D. Brandeis認為反對意見會減弱對最高法院多數意見的信任，必須把精力保留在重要案件，許多寫好的不同意見並未發表¹¹³。現任美國最高法院首席大法官John G. Roberts, Jr.受訪時表示，仿效美國知名首席大法官John Marshall推動共識判決，勸說其他大法官盡量不撰寫分別意見書，以避免弱化美國最高法院作為整體的制度正當性¹¹⁴。德國在1970年第四次修改聯邦憲法法院法引進分別意見書（Sondervotum）¹¹⁵，至2014年12月31日止，憲法法庭總共做成2,137個判決（Senatsentscheidungen），其中154個判決有一個或一個以上的分別意見書，亦即僅有7.2%的判決有分別意見書。這也是法庭內部努力尋求避免分別意見書的結果¹¹⁶。

109 Ruth Bader Ginsburg, *The Role of Dissenting Opinions*, 95 MINN. L. REV. 1, 3 (2010).

110 MELVIN I. UROFSKY, DISSENT AND THE SUPREME COURT: ITS ROLE IN THE COURT'S HISTORY AND THE NATION'S CONSTITUTIONAL DIALOGUE 63 (2015).

111 CASS R. SUNSTEIN, CONSTITUTIONAL PERSONAE: HEROES, SOLDIERS, MINIMALISTS, AND MUTES (INALIENABLE RIGHTS) 115-18 (2015).

112 WILLIAM D. POPKIN, EVOLUTION OF THE JUDICIAL OPINION—INSTITUTIONAL AND INDIVIDUAL STYLES 121 (2007); Lee Epstein et al., *The Norm of Consensus on the U.S. Supreme Court*, 45 AM. J. POL. SCI. 362, 362-77 (2001).

113 請見Ginsburg, *supra* note 109 at 6-7.

114 Jeffrey Rosen, *Roberts's Rules*, THE ATLANTIC (Jan./Feb., 2007), <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/01/robertss-rules/305559/> (last visited Aug. 2, 2016).

115 BT-Drucks. VI/388, S. 6.

116 Burkiczak Christian, in: Burkiczak/Dollinger/Schorkopf (Hrsg.), BVerfGG-Kommentar, 2015, § 30 Rn. 48 f.; 楊子慧（註15），頁72，「該院法官提出不同意見書的情況相當罕見」。林佳和，憲法法院不同意見書制度之再思考——德國經驗為中心，輔仁法學，48期，頁128（2014年）；陳淑芳，法院判決之不同意見書——德國法學界對此一問題之討論，政大法學評論，62期，頁126（1999年）；李建良，不同意見書與釋憲制度，收於：憲法理論與實踐（二），

張文貞教授研究顯示，大法官解釋「協同意見及不同意見中引用外國法和外國法院判決的數量，有大幅成長的趨勢」、「具外國留學背景的大法官，相較於未曾留學的大法官，意見書出現外國法院判決引用的頻率更高¹¹⁷」。德國聯邦憲法法院和美國最高法院的分別意見書實務相比，美國最高法院法官比較傾向於個人特色，以及分別意見書的功能，分別意見書的量也比較大。這種差異並不當然反映到我國具留學德國、或留學美國大法官撰寫分別意見書多寡上面¹¹⁸。

如上所述，大量的分別意見書乃我國特有的現象。要找出積極的標準決定，多少比例的分別意見書可以被接受為適量恐有困難。前司法院翁岳生院長強調我國司法院大法官屬於大陸法系，應該要盡可能求解釋共識¹¹⁹。學界對於不同意見書正、負功能多有論述¹²⁰。例如早期學界認為仿效英美法系的國家¹²¹公布少數意見，是「一種進步的立法¹²²」。張特生大法官則提出疑慮：「少數意見可以協同意見或不同意見方式發表……對於多數意見之權威性，終究不無影響。¹²³」蘇永欽大法官認為：「大量提出的個別意見，比起英美合議庭的分歧度毫不遜色¹²⁴」。陳新民大法官也認為解釋數量雖少，然「大法官所撰寫的許多不同或協同意見……都是一個內容

頁425-426（2000年）。

117 請見張文貞，司法院大法官解釋引用外國法及判決之實證研究——大法官留學背景作為引用的關鍵因素，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁34（2013年）。

118 翁岳生（註10），頁12；Hwang, *supra* note 86, at 41.

119 翁岳生（註100），頁359。

120 請見劉鐵錚（註93），頁12-16；劉鐵錚（註98），頁8-12；李建良（註116），林佳和（註116）頁138-162。

121 翁岳生（註100），頁359；涂浩如（註42），頁60。

122 林紀東，司法院大法官會議法之檢討，政治評論，1卷8期，頁18（1958年）。

123 張特生，大法官會議的經驗談及改進意見，憲政時代，22卷4期，頁9（1997年）。

124 蘇永欽（註75），頁92。

豐富，體系龐大的知識庫」¹²⁵。不同大法官在不同時期對於分別意見書適量與否的觀察各有其背景與意義，很難相互比較、一概而論。晚近法學界對解釋日減、分歧日增的憂慮則可被解讀為目前違憲審查正當性危機的表徵。

本文認為，高解釋門檻和分別意見書的產生，存在結構性關連。為了跨越高門檻，許多大法官策略性投票行為應運而生。實務偶爾會有為了讓三分之二多數決易於通過，技術性不出席大法官審查會，壓低出席的分母，讓案子順利通過。或者原則反對，卻為了顧全大局同意多數意見，透過所謂協同意見表達自己的立場，實際上已經構成不同意見，而非僅僅是協同意見而已¹²⁶。

肆、危機與其他制度的關連

解釋門檻以及不同意見書對和解釋危機的關連性已在本文參詳細說明。接下來要分析，其他制度對大法官策略選擇以及解釋危機之間的關連性。以下「一」說明大法官人民聲請案越多，大法官受理越少，制度正當性危機日強。以下「二」解明，大法官比較容易接受法官聲請案的策略選擇因素。以下「三」分析立法委員聲請解釋的權限，以及因立法委員選制變更而消失的危機。言詞辯論是否能提升解釋正當性將在以下「四」解明。以下「五」說明解釋做成時間的策略選擇。以下「六」藉助大法官的文獻，說明大法官非正式聯誼對合議形成的幫助，以及大法官不得連任與新人效應對合議制的影響。以下「七」解釋某些解釋橫看成嶺側成峰，與高解釋門檻要求高度妥協性的關連。

125 陳新民，如何強化憲法與基本人權「維護者」的體系功能——我國釋憲制度的今日與明日，軍法專刊，61卷3期，頁30（2015年）。

126 許宗力（註11），頁1053；蘇永欽（註46），頁13。

一、大法官對人民聲請案的選擇

「司法院大法官會議規則」時代，並未有關於人民可聲請憲法解釋之規定¹²⁷。立法院1958年制定「司法院大法官會議法」時，一方面為限制司法院大法官行使違憲審查權，另一方面則賦予人民聲請釋憲作為補償，強化立法院制訂「司法院大法官會議法」的正當性。「司法院大法官會議法」第4條規定「人民於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序，提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者」，採取奧地利法制所謂的規範憲法訴願、或不真正的憲法訴願，而不採德國人民得對法院判決或行政處分本身是否違憲提起真正的憲法訴願（Verfassungsbeschwerde）¹²⁸。

第四屆大法官在威權統治時代，人民聲請釋憲功能並不特別突出，司法院大法官做出兩次宣告判例違憲、一次宣告司法院舊解釋應予變更，並做成4個補充解釋，但並未宣告任何法律或命令違憲。自第五屆大法官以來，大法官因勢利導，擴大人民聲請違憲審查的對象，並透過解釋，建構解釋的拘束力體系，司法院大法官因人民聲請釋憲宣告法律或命令違憲的解釋案件數量日益龐大。「司

127 以上請見楊與齡（註43），頁332-336。

128 涂浩如（註42），頁50-53。真正的基本權利訴願（echte Grundrechtsbeschwerde）與不真正的憲法基本權利訴願（unechte Grundrechtsbeschwerde）有共同特徵，兩者都是在個人於其憲法上所保障之權利，遭受直接不法侵害，經窮盡一般救濟途徑（Erschöpfung des Rechtswegs）之後，向憲法法院或其他類似機構提起（如憲法法庭或我國的大法官）特別的基本權利救濟。兩者的根本差別在於，真正的基本權利訴願乃針對公權力侵害基本權利的個別行為，這些行為可能包括立法機關的行為（法律、國際條約的批准或決議）、行政行為（法規命令、職權命令或行政規則、行政處分、甚至事實行為）以及法院的判決。不真正的基本權利訴願並不針對個別法適用行為提起訴願，而是針對個別法適用行為之基礎法律，或命令發生有牴觸憲法之疑義時，所提起之救濟行為。真正的基本權利訴願與不真正的憲法基本權利訴願的區別請參考Georg Brunner, Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum, in: Baer/Lepsius/Schönberger/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge, Bd. 50, 2002, S. 191 (203 ff.).

法院大法官審理案件法」於1993年制定公佈後，於第5條第2項第2款規定新增法人與政黨可以提請憲法解釋¹²⁹，此項規定經立法委員陳水扁提議後增列¹³⁰。立法之時，我國正值民主轉型，民進黨尚有被執政黨解散之虞，故由陳水扁委員提議藉由基本權利訴願之制度，保障政黨（反對黨）權利¹³¹。

自司法院釋字第313號解釋以後，扣除統一解釋不算。大法官做成的解釋中，以人民聲請者居絕大多數，共324件，佔79.8%（請見圖9）¹³²。尤其高達48.5%的案件中，司法院大法官會宣告法律、命令、或其他國家行為違憲。本來是為了平衡立法院限制違憲審查權引進的制度，在民主化之後，因整個國家權力都需得到某種程度的人民支持，尤其是定期選舉的選票肯定。大法官雖無連任壓力，卻也受到廣大公共領域監督，不可忽視人民對違憲審查的渴望。然而隨著大法官受理案件日少，越多的人民聲請案，將產生越多的程序駁回，帶來更多人民的失望，甚至撼動違憲審查制度的正當性。在此背景下，憲法訴訟法第59條引進德國裁判憲法審查（憲法訴願）制度，「人民就其依法定程序用盡審級救濟之案件，對於受不利確定終局裁判，認有牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為違憲宣告之判決¹³³。」伴隨著違憲解釋門檻降低，新的裁判憲法審查能否提高人民對憲法法庭的信賴，仍有待實務檢驗。

129 以上請見楊與齡（註43），頁325以下。

130 立法院公報，82卷2期，頁380，委員會紀錄（1993年）。

131 翁岳生教授早已指出，我國此種法制與德國法不盡相同。德國基本法第21條規定，政黨為憲法機關，因此當政黨要主張其基於憲法上所賦予之特殊地位時，必須循聯邦憲法機關權限爭議（Organstreit）途徑。請參翁岳生（註36），頁434註35。請另參Klaus Schlaich/Stefan Koriath, Das Bundesverfassungsgericht, 5. Aufl., 2001, Rn. 84. 詳細說明，請另見陳英鈐，基本權利訴願的結構性變遷——從比較法論基本權利訴願的對象與判決拘束力，收於：憲政民主與人權，頁88-89（2004年）。

132 蘇永欽（註75），頁93。

133 大法官書記處，憲法訴訟法三讀通過，釋憲制度開展新紀元，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=396181>（最後瀏覽日：2019年12月1日）。

聲請人	解釋數量	百分比
人民	324	79.8%
法官	31	7.6%
立委	35	8.6%
行政院	3	.7%
監察院	4	1.0%
考試院	3	.7%
地方機關	1	.2%
總統	3	.7%
國民大會	2	.5%
總數	406	100.0%

圖9 聲請人類別佔申請案件數及其比例

資料來源：作者自製。

◎由釋字313號開始計算，且扣除統一解釋之釋字

◎一案件之聲請人可能有兩者以上，圖9統計表為複選次數分配表

二、大法官對法官聲請案的選擇

受限於大法官有限解釋數量，大部分沒被司法院大法官青睞的案件，都被程序駁回。有些聲請人不滿司法院大法官不附理由，或者簡單地以不符司法院大法官審理案件法第5條第1項為由駁回¹³⁴。對外界而言，大法官不受理的決議仍然猶如黑盒子。這種不滿，有時也出現在法官停止審判、聲請釋憲案件。桃園地院法官錢建榮曾質疑大法官不受理理由常為「『空泛指摘』聲請人的聲請理由是『空泛之指摘』，卻不敢一併公開聲請書及承辦大法官以供外界檢

¹³⁴ 司法院網站，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=209086>（最後瀏覽日：2016年8月15日）。

驗。¹³⁵」不過人民聲請釋憲和法官聲請釋憲對司法院大法官的策略行為還是產生不同影響。

本文的統計發現，整體案件出現協同意見書的機率是41.9%，而法官聲請解釋出現協同意見書的機率是65.8%，明顯高出許多（請見圖10）。一種可能的解釋是，法院聲請憲法解釋，必須「提出客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」，「應於聲請書內詳敘其對系爭違憲法律之闡釋，以及對據以審查之憲法規範意涵之說明，並基於以上見解，提出其確信系爭法律違反該憲法規範之論證，且其論證客觀上無明顯錯誤。¹³⁶」相對於一般人民聲請釋憲案件，在前述司法院釋字第371號、第572號解釋的高門檻下，停止審判、聲請釋憲的法官對案件事實相當瞭解，並且對於系爭法律是否違憲的爭點也必須詳細說明，這不僅有助於司法院大法官決定是否受理案件，也能讓大法官快速就爭點進行審議，甚至對於協同意見書的撰寫節省了很多時間和勞力，因此法官聲請釋憲出現協同意見書的機率比較高¹³⁷。

135 請見錢建榮，大法官的不受理決議應受公議，蘋果日報，2012年7月26日，<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20120726/34395203/>（最後瀏覽日：2016年8月15日）。立法委員王惠美質詢時，有同樣疑慮，請見立法院公報，102卷23期，頁220，王惠美委員發言（2013年）。

136 請見司法院釋字第371號、第572號解釋。廖義男（註55），頁56-57。林子傑，認識大法官解釋的第一本書，頁249（2011年）。

137 以上見解為作者訪問大法官A時所認同。大法官C與作者非正式訪問時，亦認同上述看法。

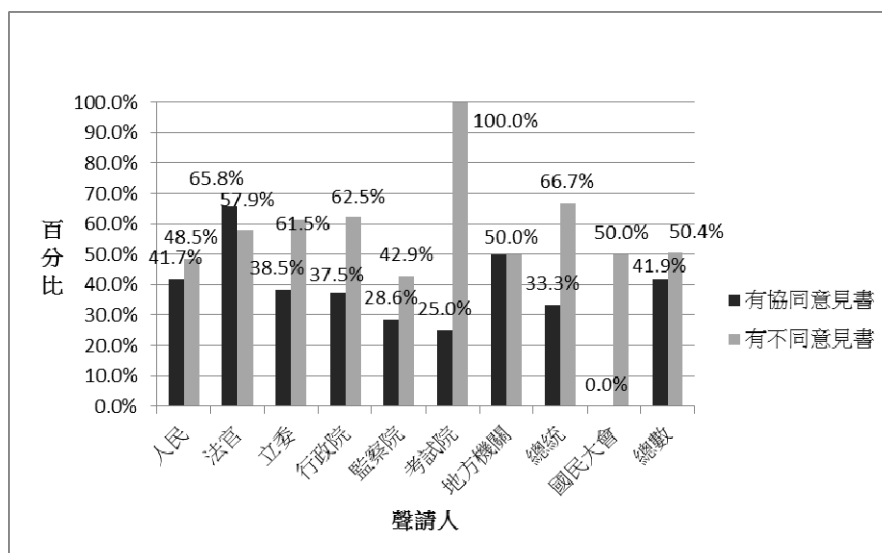


圖10 不同聲請人與分別意見書出現的比例

資料來源：作者自製。

三、大法官對立法委員聲請案的選擇

接下來分析少數立委聲請釋憲對大法官策略行為的影響。大審法第5條第1項第3款規定：「依立法委員現有總額三分之一以上之聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。」該款規定顯然係參考德國基本法，賦予少數黨議員聲請釋憲，以解決政黨政治爭議，建立正常且合理的憲政秩序¹³⁸。與德國法制不同的是，「我國法制，對於國會議員聲請釋憲之規定，雖有『行使職權』、『適用法律』等條件之限制，……實務之發展，立法委員得聲請釋憲之事項，不僅法律是否牴觸憲法之疑義而已，而且可涉及法規命令及編列之預算案是否牴觸憲法之疑義，甚

¹³⁸ 司法院，大法官釋憲史料，頁245（1998年）；立法院公報，82卷2期，頁380-382、396，陳水扁委員發言（1994年）。

至包括立法委員行使職權是否涵蓋之權力事項，顯較德、奧法制寬廣甚多。¹³⁹」

隨著政黨政治的形成，以及大審法引進三分之一以上立法委員得連署聲請疑義解釋，反對黨屢屢將重大政治爭議問題的戰場，延伸至大法官會議，爭取對自己有利的遊戲規則¹⁴⁰。陳水扁當選與連任總統之後，民進黨從未掌握立法院絕對多數，三分之一以上立法委員聲請也成了對抗立法院多數（國民黨與親民黨）的利器¹⁴¹。在民主化的過程中，李登輝主政初期政黨勢力重組，陳水扁執政時期行政、立法二元分立，司法院大法官利用這種政治多元的空間，取得相對於政治勢力的自主解釋空間。

2005年第七次修憲之後，立法院三分之二的席次（73人）由區域代表選舉產生。2007年立法委員選舉，反對黨立法委員遠遠不足總額三分之一（38席），無法依據本項聲請解釋。直到2012年立法委員改選前，最後一件三分之一以上立法委員聲請釋憲，由立法委員陳金德等85人於2004年1月4日聲請解釋公民投票法違憲，司法院大法官於2008年7月11日做成司法院釋字第645號解釋，宣告公投法中立法院有公投提案權並不違憲，但公投審議委員依政黨比例組成的任命規定違憲。2012年9月17日，立法委員柯建銘等46人，就立法院臨時會得否提出對行政院院長不信任案聲請釋憲，大法官則於2016年2月4日做出司法院釋字第735號解釋，認為「立法院於臨

139 詳細說明請見司法院釋字第603號解釋廖義男大法官協同意見書。

140 進一步說明請見陳英鈐，憲法機關權限爭訟，收於：憲政民主與人權，頁1（2004年）；翁岳生（註53），頁93-95；Hwang, *supra* note 86, at 48-49.

141 德國的機關權限訴訟可以由國會議員個人或議會黨團提起，已成為國會少數黨對抗國會多數黨的憲法武器，請見Anuscheh Farahat, Das Bundesverfassungsgericht, in: Bogdandy/Grabenwarter/Huber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, Ius Publicum Europaeum, Bd. VI, 2016, § 97, Rn. 75-76; Klaus Stüwe, Bundesverfassungsgericht und Opposition, in: Ooyen/Möllers (Hrsg.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2. Aufl., 2015, S. 351-354.

時會中審議不信任案，非憲法所不許」。換句話說，在長達約7年半的時間，並無三分之一以上立法委員聲請釋憲做成之解釋。以致社會的多元意見，無法透過少數黨聲請違憲審查，取得發言管道¹⁴²。

總數35件的立委聲請案中¹⁴³，聲請釋憲的結果顯示，高達62.9%的案件違憲，比人民聲請的案件48.5%違憲高出許多（請見圖11）。本文推測，司法院大法官受理立法委員聲請釋憲的可能性也高於人民聲請的比例。因2005年憲法修改立法委員產生方式，造成立法院反對黨無法達到聲請釋憲的三分之一門檻，應該也是造成司法院大法官解釋案件減少的因素之一。

憲法訴訟法第49條規定，立委現有總額四分之一以上，就其行使職權，認法律位階、法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。將立法委員聲請釋憲的門檻由三分之一降低為四分之一，現制立委釋憲門檻113人的三分之一是38人，新制降為四分之一是29人¹⁴⁴。新制可望增加國會少數黨透過聲請釋憲制衡國會多數黨的機率¹⁴⁵。至於會產生什麼樣的影響，仍有待實務檢驗。

¹⁴² 類似看法，請見許宗力（註11），頁1041。

¹⁴³ 分別是司法院釋字第325、328、329、334、342、351、357、364、365、371、380、387、388、391、392、401、419、421、426、435、436、447、450、461、463、467、472、481、485、499、543、585、599、601、603、632、633、645號解釋。

¹⁴⁴ 溫貴香，釋憲門檻降為立委總額1/4人民可個案聲請釋憲，中央通訊社，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201812180279.aspx>（最後瀏覽日：2020年6月20日）。

¹⁴⁵ 立法委員吳志揚：「這項修正將增加國會少數黨制衡多數黨之機會，建立正常且合理的憲政秩序。」請見周毓翔，立委申請釋憲門檻降到1/4 吳志揚：有助制衡多數黨，中時新聞網，2018年12月18日，<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20181218003614-260407>（最後瀏覽日：2020年6月20日）。

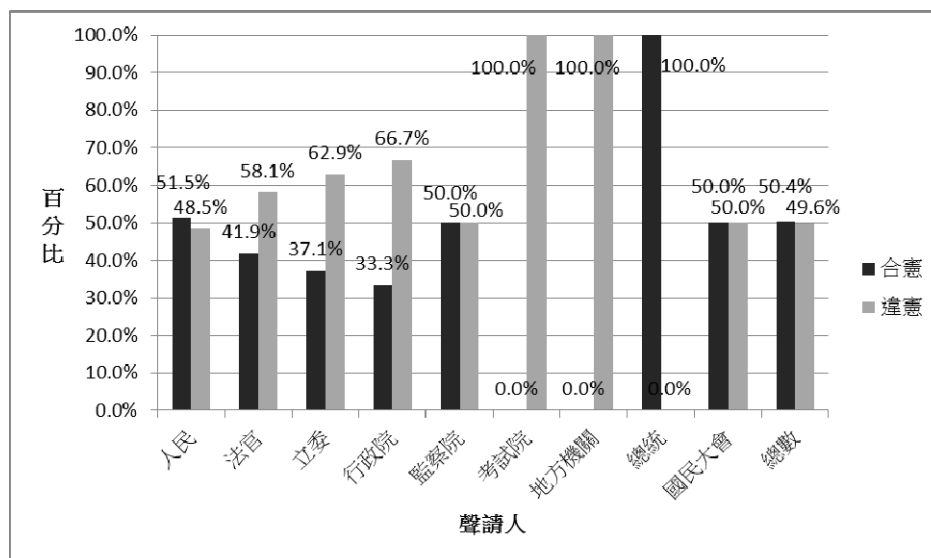


圖11 不同聲請人與解釋合憲或違憲比例

資料來源：作者自製。

四、言詞辯論與解釋正當性

配合1992年憲法增修條文新增規定，1993年的大審法第三章規定政黨違憲解散案件由憲法法庭審理，大審法第21條要求憲法法庭應本於言詞辯論才能做成裁判。須有大法官現有總額四分之三以上出席，憲法法庭才能進行言詞辯論（大審法第24條）。未參與辯論之大法官不得參與政黨違憲解散案件之評議判決。第25條進一步要求，須有參與言詞辯論大法官三分之二以上同意，憲法法庭才能做出政黨違憲解散案件判決之評議（第1項）。評議未達第一項高門檻，應為不予解散之判決（第2項）。但駁回政黨違憲聲請，僅須有大法官現有總額四分之三之出席，及出席人過半數之同意即可（第3項）。此項政黨禁止制度，係仿照德國基本法第21條第2與第3項，

透過憲法法庭的高門檻審查，保障反對黨的政黨存續¹⁴⁶。實際上，政黨禁止制度自入憲後，並無實際應用案例。1993年大審法修訂時，趁著憲法法庭設立之便，大審法第13條規定，大法官解釋案件，必要時得準用憲法法庭言詞辯論之規定，為言詞辯論¹⁴⁷，開啟司法院大法官行言詞辯論的大門。

司法院網站認為「透過法庭辯論程序的公開呈現，不但使案件之爭點及論證更明晰，且有助於強化釋憲功能。」言詞辯論可能有助於大法官消弭歧見，達成共識，但也有可能強化大法官既有的立場，在合議制的前提下，面對受理案件後，解釋結果的不確定性，大法官如何看待言詞辯論將影響其策略選擇。許宗力大法官認為南非前大法官Albie Sachs對南非憲法法院判決的描述也同樣適用於我國司法院大法官：「判決的撰寫就像是一趟旅程，始於最具嘗試性的大膽想法，經過徹底的懷疑和論辯，最終排除所有的可能錯誤，獲致經得起考驗的結論。」許宗力院長進一步認為「『判決是不同元素間權衡交融過程後的產物』。需要法官有『包容之心』，不斷地調適修正的態度，加上合議制，平衡不同人的偏見與偏好，以最大可能提升判決在當其時當其地的說服力。¹⁴⁸」倘若上述描述真能契合司法院大法官解釋憲法的實際審議程序，那麼言詞辯論應該有助於大法官尋求共識¹⁴⁹。

146 請參立法院公報，82卷2期，頁400（1993年）；Tom Ginsburg et. al., *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Courts in Asian Cases*, 3 NTU L. REV. 143, 153 (2008).

147 請見司法院函送立法院「司法院大法官會議法部分條文修正草案」說明，立法院第1屆第90會期第9次會議議案關係文書，頁21（1992年）。

148 許宗力，俠義法律人奧比·薩克斯大法官，收於奧比·薩克斯著，陳毓奇、陳禮工譯，斷臂上的花朵，頁17（2014年）。吳庚大法官以哲學家H. G. Gadamer的詮釋循環來描述司法院大法官的審查過程。請見，吳庚（註53），頁361-362；同樣對言詞辯論持正面態度，蘇永欽，司法院大法官審理案件法修正芻議，收於：尋找共和國，頁293-294（2008年）。

149 立法委員尤美女認為，大審法應修改為，人民聲請解釋案件言詞辯論為原則，不經言詞辯論為例外。請見立法院公報，102卷23期，頁214，立委尤美

迄今司法院大法官總共舉行9次言詞辯論，皆為社會大眾矚目案件。分別為司法院釋字第334號解釋（83年1月14日）政府公債是否包括政府賒借；司法院釋字第392號解釋（84年12月22日）檢察官是否有羈押權；司法院釋字第419號解釋（85年12月31日）副總統得否兼任行政院長；司法院釋字第445號解釋（87年1月23日）集會遊行法三原則是否違憲；司法院釋字第585號解釋（93年12月15日）真調會是否違憲；司法院釋字第603號解釋（94年9月28日）請領身份證是否需按指紋；司法院釋字第689號解釋（100年7月29日）狗仔跟追能否處罰；司法院釋字第711號解釋（102年7月31日）藥師執業處以一處為限是否違憲¹⁵⁰；司法院釋字第737號解釋（105年4月29日）涉及偵查中羈押審查程序中，犯罪嫌疑人及其代理人能否閱卷獲取資訊。在這九件解釋當中，除了司法院釋字第334號解釋為立法院所聲請之統一解釋，形式上無明顯合憲或違憲之外，其他8件解釋結果都是違憲或部分違憲。

如果過去的經驗可以作為未來預測的參考，那麼可以說，一旦司法院大法官決定進行言詞辯論，該案件宣告法律、命令或政府行為違憲的機率相當高。經統計分析，司法院大法官有無進行言詞辯論和是否做成合憲或違憲解釋有關連。此外，統計分析還發現，司法院大法官有無進行言詞辯論和是否有協同意見書沒有關連，亦即進行言詞辯論既不會增加、也不會減少出現協同意見的可能性。但有無進行言詞辯論和是否有不同意見書有顯著關連，亦即一旦司法院大法官經過言詞辯論再做成解釋，必然出現不同意見書（請見圖12）。大法官陳瑞堂很早就批評，大法官尚未審理之前，分案大法官即寫好解釋文，可能造成大法官「先入為主，抱持成見，而影響

女發言，委員會紀錄（2013年）。

150 司法院網站，http://www.judicial.gov.tw/ByLaw/law_ch_class1_2.jsp?pretext=&page_str=4（最後瀏覽日：2015年12月1日）。

集思廣益¹⁵¹」。據筆者訪問 A 大法官表示，司法院大法官藉由言詞辯論一方面顯示自身為法庭，二方面爭取社會大眾認同解釋結果。B 大法官則認為不能由本文統計結果，認定司法院大法官在決定言詞辯論之前，已有先入為主，系爭法律、命令或政府行為違憲¹⁵²。

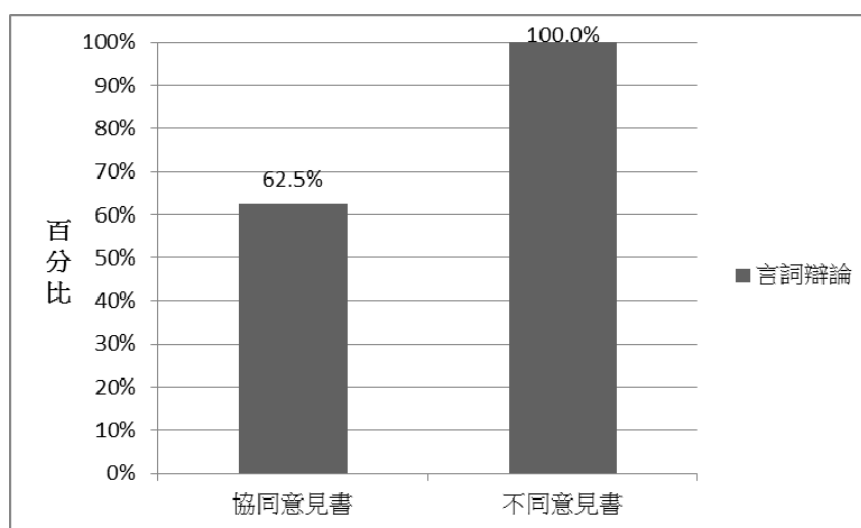


圖12 言詞辯論案件協同與不同意見書比例

資料來源：作者自製。

為什麼決定言詞辯論的案件，結果都是違憲？本文推測，這和審理程序有關。大法官Elena Kagen表示，依她的經驗，美國最高法院的言詞辯論有可能強化大法官先前對案件的看法，也有可能改變言詞辯論之前的觀點。和臺灣不同的是，美國最高法院在舉行言詞辯論之前，大法官不會開會討論案件內容，因此尚未初步形成多數

¹⁵¹ 陳瑞堂，釋憲制度中有關程序運作方式的問題，憲政時代，22卷4期，頁17（1997年）。

¹⁵² 到底法律論證能否影響判決結果，請另見SUNSTEIN, *supra* note 25, at 133-34.

意見。大法官在辯論過程中，透過對於上訴人或相對人的詢問，強化或質疑某種觀點，就是一種和其他大法官溝通的重要方式¹⁵³。首席大法官John G. Roberts, Jr. 研究28個美國最高法院的案件（1980年的14個案件和2003年的14個案件）後發現，其中24個案件（86%），法官在言詞辯論中向敗訴方問了更多的問題。因此首席大法官認為，最高法院律師「成功辯護的秘訣就是讓法院向你的對手提出更多問題。¹⁵⁴」在有限的時間之內，要說服其他大法官，最好的方式就是在言詞辯論中暴露相反意見的弱點，因此言詞辯論中，被問比較多次的一造有可能會輸¹⁵⁵。

我國司法院大法官決定舉行言詞辯論與否，繫於其程序裁量。言詞辯論有可能改變不同意見，也有可能強化既有立場，甚至擦出火花。若多數意見認為本案合憲，縱然理由不同，他們可以透過協同意見書表達立場，沒必要為了統一理由舉行言詞辯論，更無動機為了讓聲請人說服自己改變立場而舉辦言詞辯論。反之，若多數大法官認為本案違憲或部分違憲，為了說服其他持不同意見的大法官或者大眾，舉辦言詞辯論是個可能的策略選項。很有可能言詞辯論後，大法官經過相互說服或妥協達成多數意見後，少數大法官仍無法完全被說服，因此發表不同意見書表示各人意見的比例達到100%。反之，發表協同意見書的比例為62.5%。

五、解釋時間的策略選擇

前司法院秘書長林錦芳在立法院答詢時表示，從司法院釋字第670到第707號解釋三年間總共38號解釋，平均結案日為692.71天。根據林秘書長，耗時這麼久的一項原因為「除了解釋文要經過評議

153 C-SPAN, <https://www.c-span.org/video/?c4477855/supreme-court-justices-decision-making-process> (last visited Aug. 10, 2016).

154 See John G. Roberts, Jr., *Oral Advocacy and Re-emergence of a Supreme Court Bar*, 30 J. SUP. CT. HIST. 75 (2005).

155 學界的研究請見EPSTEIN, *supra* note 28, at 305-36.

以外，理由也要逐字、逐段的去評議，所以在討論理由的時候花了非常多的時間。¹⁵⁶」這也可說明，當多數大法官認為案件合憲，傾向於程序不受理，免得花費大量心神，排擠違憲解釋的能量。以下進一步說明司法院大法官解釋的策略選擇和時間因素的關連性。

由於司法院網站公布的解釋資料不齊全，早期解釋的聲請時間至今許多已不可考，本文選擇自司法院釋字第313號解釋開始統計至司法院釋字第739號解釋為止，共427個案件，其中仍有19筆資料不知聲請時間，無法計算歷經天數¹⁵⁷。司法院大法官做成一件解釋平均（mean）花費767.59天（2.1年），中位數（median）為730天（兩年）（請見圖13、圖14）。

¹⁵⁶ 請見立法院公報，102卷23期，頁206，委員會紀錄（2013年）。

¹⁵⁷ 從司法院網站公布的解釋聲請書只能得知以下解釋做成年、月份，不知確切解釋日期，本文一律推定為當月15日。詳細說明如下：司法院釋字第213號解釋：民國74年5月；司法院釋字第216號解釋：民國73年10月。司法院釋字第221號解釋：民國75年2月。司法院釋字第414號解釋：民國84年5月。司法院釋字第420號解釋：民國84年5月。司法院釋字第422號解釋：民國83年5月。司法院釋字第427號解釋：民國83年9月。司法院釋字第693號解釋：民國97年10月。

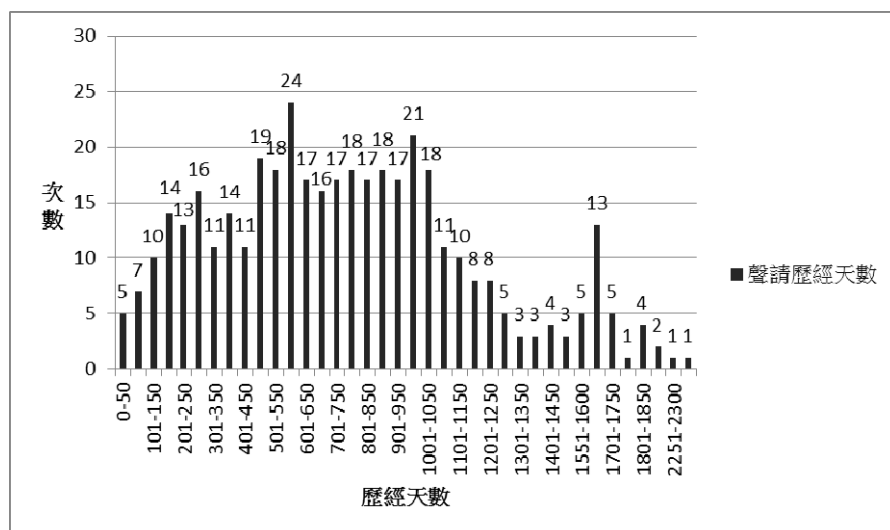


圖13 聲請歷經天數次數分配表

資料來源：作者自製。

圖表說明：歷經天數分類方式為50天為一個區間

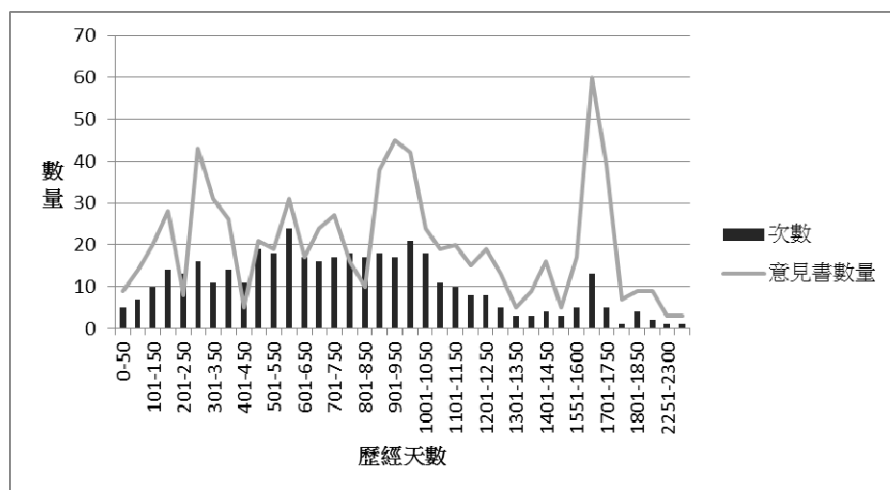


圖14 歷經天數與意見書數量比較圖

資料來源：作者自製。

早期司法院大法官解釋曠日廢時，司法院釋字第166號解釋關於違警罰法授權警察官署裁決之拘留、罰役，侵犯人身自由而違憲，自監察院聲請至做成解釋共7079日，近二十年¹⁵⁸。從司法院釋字第313號解釋開始觀察，司法院釋字第470號解釋歷經時間最短，此案乃關於憲法修改後，總統府聲請解釋，如何任命司法院正、副院長，總統府主張有急迫性，因事涉司法院正、副院長行使職權的正當性，司法院大法官火速做成解釋，僅花24天。司法院釋字第644號解釋歷經時間最長，耗費2569天（7年又14天）。本案涉及陳師孟籌組社會團體「臺北市『外省人』臺灣獨立促進會」，經臺北市政府社會局申以違反人民團體法第2條規定「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土」否准，陳師孟於2001年6月8日聲請解釋，本案雖觸及民主轉型中的統、獨認同敏感神經，但有超過半數大法官認為應該受理，卻無法達成三分之二門檻。2003年新任大法官上任仍無法做成解釋，直到2008年6月20日司法院大法官才宣告，人民團體法對主張共產主義、分裂國土之團體不許可設立規定違憲。

司法院釋字第392號解釋關於檢察官羈押權的解釋其次，歷時2261天（6年又71天）。本案聲請人許信良被列黑名單，1989年9月27日涉嫌偷渡入境及所謂叛亂通緝，遭當時之臺灣省高雄港務警察所逕行逮捕並羈押，其委任律師陳水扁聲請提審被駁回，乃於1989年10月13日聲請釋憲。其後，立法委員李慶雄等17人（包含立法委員陳水扁）於1992年6月9日向立法院提案聲請釋憲。緊接著立法委員張俊雄等52人也於1995年7月18日聲請釋憲，主張舊刑事訴訟法第102條第3項及同法第71條第4項規定，賦予檢察官羈押被告權限，牴觸憲法第8條。臺中地方法院法官高思大也在1995年8月28日聲請釋憲，認為依憲法檢察官不能自行決定羈押。本案有超過二分

¹⁵⁸ 翁岳生（註53），頁24。

之一以上大法官認為應該受理，但無法快速達成三分之二解釋共識；或者雖有超過三分之二多數認為違憲，但在民主轉型期間，為強化解釋正當性，司法院大法官乃於1995年10月19日及11月2日首次召開憲法法庭，舉行言詞辯論。1995年12月22日做成司法院釋字392號解釋。

統計分析顯示，歷經天數和不同意見書之間沒有相關性，但歷經天數和協同意見書之間是有相關性的（請見圖15）。本文統計完全以形式上大法官個人標示為協同或不同意見為準。司法院大法官受理案件後，若無法達成解釋所需門檻，就只能耗著，甚至成為死案，石沈大海。大法官面對需要高門檻的案件，如上述司法院釋字第392或第644號解釋，需要比較大的妥協才能做出解釋。因此某些多數意見「實質上」可能為部分反對意見，勉強達成妥協後，為了表明個人真正意見，形式上只能發表協同意見，實質上為反對意見以明志。

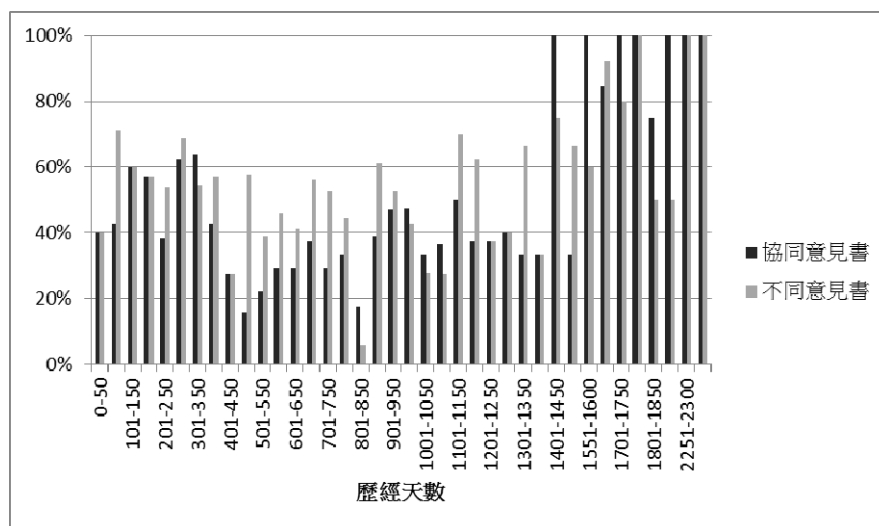


圖15 歷經天數與有無意見書之交叉分析

資料來源：作者自製。

六、合議制變化與互動策略

個別大法官是否考量合議制運作精神會影響大法官是否撰寫分別意見書。第四屆大法官中，姚瑞光與陳世榮兩位大法官是不同意見書的常客¹⁵⁹。「第四屆9年有54或55個不同意見書，這兩位包辦差不多50個左右。¹⁶⁰」其他大法官為了克服門檻障礙，於是在審查會之前舉行會外會，以求達成四分之三解釋共識¹⁶¹。「第五屆大法官每三個月自費聚餐一次，有時還攜眷參加，以化解同仁間因執行公務而發生之誤會，並能增進議事之效率。¹⁶²」前大法官翁岳生以下這段話頗能描繪合議制運作的精髓：

大法官的工作是合議制，我擔任大法官時不敢自認為自己的見解就是真理，不敢要求其他大法官要完全照我的意思通過，只要大原則符合就好。」「人要十全十美，尤其在一個合議制的制度裡，是很困難的。我也很少寫不同意見書，我要想推動案子通過，自己更不應該為了要表達個人意見去寫，這樣以後你講的話別人就不一定要接受。

史錫恩大法官曾表示「大多數法官一次更換，對辦案經驗傳承亦甚為不利，第五屆大法官前三年公布解釋較少，即可獲得證明。¹⁶³」2003年以後大法官不分屆、別，不得連任。2003年任命的大法官，有六位是第六屆大法官連任，九位新任。2007年有四位大法官就任，2008年五位大法官上任、2010年蘇永欽、賴浩敏兩位大法官就任、2011年又有四位大法官上任、2015年10月四位大法官就

159 湯德宗，大法官解釋不同意見的實證研究，收於：違憲審查與動態平衡：權力分立新論（卷二），增訂四版，頁430（2014年）。

160 請見翁岳生（註78），頁14。

161 翁岳生（註53），頁145。

162 請見翁岳生（註78），頁12。史錫恩，我國釋憲制度之檢討與改進，收於：楊建華教授七秩誕辰祝壽論文集編輯委員會編，法制現代化之回顧與前瞻——楊建華教授七秩誕辰祝壽論文集，頁202（1997年）。

163 史錫恩（註162），頁204。

任。不斷有新大法官上任，「新人效應」(freshman effect)¹⁶⁴使得合議制精神弱化，大法官之間彼此將不同意見表面化的意願更強。

2003年以後與第四屆大法官在分別意見書的發表上便有很大差異¹⁶⁵。2003年任命的大法官，有六位是第六屆大法官連任的，連任的大法官發表個別意見書的機率比較低，其他九位新任的大法官對於不同意見書的發表比較積極，尤其新任大法官協同意見書的發表量皆高於連任大法官。這也印證了翁前院長的觀察，現制大法官任期僅有八年，無法連任，大法官「比較沒有團隊歸屬感」，「個人意識比較強，想要有所作為，比較積極，想要在任期內有良好的表現」，影響大法官勤於撰寫分別意見書¹⁶⁶。合議制精神弱化成為目前違憲審查危機的根源¹⁶⁷。面對高解釋門檻，許多大法官在費盡九牛二虎之力達成妥協後，要寫不同或協同意見書明志，這又造成分別意見書的增長。

合議制精神如何影響大法官的溝通，可以司法院釋字第261、第627以及第632解釋為例說明。遇有重大爭議案件，美國最高法院會力求全體大法官一致，共同承擔政治與社會壓力，提升判決的正當性與說服力，降低社會衝突¹⁶⁸。司法院釋字第261號解釋第一屆中央民代退職案，原本大法官意見分歧，大法官全體審查會主席翁岳生大法官突然休克不省人事送醫後，司法院長林洋港「以及其他同仁紛紛來探望，大法官們都私下安慰我，事情一定會解決。」在強大的政治社會壓力（野百合學生運動）下，大法官旋即互相讓

164 美國最高法院大法官新人效應研究請見Timothy M. Hagle, "Freshman Effects" for Supreme Court Justices, 37 AM. J. POL. SCI. 1142, 1142-57 (1993).

165 大法官的司法行為模式2003年前、後並不相同，請見Hwang, *supra* note 86, at 62; Yen-tu Su & Han-wei Ho, *The Causes of Rising Opinion Dissensus on Taiwan's Constitutional Court*, 4, <http://idv.sinica.edu.tw/yentusu/su2016e.pdf> (last visited Aug. 10, 2016).

166 翁岳生（註10），頁12。

167 翁岳生（註10），頁13。

168 翁岳生（註37），頁303；翁岳生（註41）；翁岳生（註53），頁49。

步，達成共識，沒有任何不同意見書¹⁶⁹。同樣地，靠著「大法官以外其他人員都不要到場」，不預設立場，充分溝通，司法院釋字第627號解釋關於總統國家機密特權的解釋，也沒有不同意見書或協同意見書。同樣的方法用到司法院釋字第632號解釋監察委員同意權案，則仍有分別意見書產生。翁岳生大法官認為，這是因為任期4年的8位大法官做到司法院釋字第633號解釋任期就到了，沒有充分時間溝通¹⁷⁰。

七、橫看成嶺側成峰

在高門檻限制下，為了做成解釋，司法院大法官可以透過「警告性解釋」和模糊解釋達成策略妥協。「警告性解釋」既未宣告法令違憲，並不具有權利救濟功能。其主要成因亦和大法官作成憲法解釋高門檻有關。當多數大法官認為法律違憲，卻無法達到三分之二門檻，只好做成警告性解釋¹⁷¹。

模糊解釋也是大法官策略選擇的另一選項。前司法院秘書長楊仁壽在司法院釋字第553號解釋記者會上脫口而出，這件解釋對中央或地方來說，是「橫看成嶺側成峰」，沒有誰輸誰贏的問題¹⁷²。從此，大法官會議對許多重大政治爭議的解釋總是被外界以「橫看成嶺側成峰」形容。有的論者認為，大法官在重大政治爭議上明哲保身，不願選邊站，以保持自身中立的地位¹⁷³。模糊解釋乃創造政治部門雙贏與對話的不二法門，明知模糊解釋會造成解讀困難，甚

169 翁岳生教授致詞，收於：黃昭元編，*法治的傳承與永續——第一屆翁岳生教授公法學研討會論文集*，頁ix（2013年）。

170 請見翁岳生（註78），頁15。

171 請參廖義男，*司法院大法官解釋之權利救濟功能*，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，*審判獨立與權利救濟、行政訴訟之發展與變革——海峽兩岸公法學論壇論文集（三）*，頁13（2016年）。

172 社論，*大法官踢皮球？人民敗給這群「訓練有素的無能」*，台灣日報，2012年12月22日。

173 GINSBURG, *supra* note 31, at 151.

至違反法治國法明確性原則界線的批評，司法院大法官在許多解釋仍然選擇含糊其詞。橫嶺側峰可能是大法官解釋高門檻下，不得不然的產物，同時給政治部門妥協空間¹⁷⁴。解釋越模糊，政治部門遵守憲法解釋的迴旋空間越大，解釋寫成「橫看成嶺側成峰」，爭議的政治部門各自解讀大法官解釋，表面上有面子，皆可宣稱贏家。反之，若解釋越清楚，政治部門輸贏一目了然，違憲的一方政治成本越高，不遵守解釋的可能性越高。引發政治報復的動機越強¹⁷⁵，例如司法院釋字第76號解釋。

部份大法官則對此模稜兩可的解釋大表不滿。例如前大法官陳瑞堂曾慨言：「為打開僵局有時不得不妥協酌採少數意見，勉強通過解釋案，如此又難免發生理論不一致，或解釋文及理由不協調等後遺症。¹⁷⁶」劉鐵錚大法官司法院釋字第553號解釋不同意見書嚴厲批評：「大法官在本件解釋案，作出似結論又非結論之判斷，與釋字第419號解釋之模稜兩可，釋字第52號解釋之模糊不清，如出一轍，未能及時發揮大法官解釋釐清爭議之功能，置機關間爭議久懸而不決，令人可作不同之解讀，本席難以苟同。¹⁷⁷」許宗力大法官在司法院釋字第579號解釋不同意見書即對多數意見究竟是合憲還是違憲表示費解。司法院釋字第606號解釋大法官許玉秀不同意見書慨嘆：「本號解釋是一個難以理解的解釋，……大法官也認為聲請人憲法上權利沒有受到限制，但竟然也可以作成解釋！」湯德宗大法官更是在司法院釋字第692、694、696號解釋不同與協同意見書當中，抨擊多數意見不肯採納美國式三層審查標準，以二元連動方式來決定規範是否違憲，而以比例原則進行「赤裸裸的利益衡量」。

174 關於違憲審查策略行為選擇模糊意見的理論說明，請見Jeffrey K. Staton & Georg Vanberg, *The Value of Vagueness: Delegation, Defiance, and Judicial Opinions*, 52 AM. J. POL. SCI. 504, 504-19 (2008).

175 對於美國最高法院與德國聯邦憲法法院模糊解釋的策略選擇，see *id.* at 507.

176 陳瑞堂（註151），頁14。

177 請見司法院釋字第553號解釋劉鐵錚大法官不同意見書。

大法官「警告性解釋」和模糊解釋都是策略行為的產物，有些解釋達成妥協困難，造成解釋減產。縱使做出解釋，這些解釋內在邏輯矛盾，看起來比較像是政治的暫時妥協（*modus vivendi*），而不是對結論有重疊共識（*overlapping consensus*），只是支持的理由或理論不同而已¹⁷⁸。儘管寫分別意見書也要付出成本，尤其對於合議制精神的破壞，對於未來爭取其他大法官支持自己的見解構成負擔。2003年以後任命的大法官合議制精神弱化，撰寫分別意見書的意願更強。模糊的解釋造成「對立的雙方都認為自己勝訴，這樣司法權威性是不夠的¹⁷⁹。」固然，政治部門可各自宣稱勝訴，不必因過於模糊的憲法解釋付出任何政治代價，司法院大法官卻得付出代價。既然解釋無關痛癢，甚至「被譏為有解釋不如無解釋者亦有之¹⁸⁰」。對於一般人民而言，越多的分別意見書，只是造成更多的分歧，理解司法院大法官意見的困難。對於堅守法與政治典範者而言，司法與政治的決策模式兩者不容混淆¹⁸¹。大法官D受訪時表示，大法官內部表決，有時理論根本不重要，重要的是能否爭取到過門檻的策略聯盟。所謂橫看成嶺側成峰，使得外界分不清大法官與立法委員的差別，容易混淆司法與政治的界線。難怪會形成連部分大法官都無法認同的危機。

178 所謂重疊共識，請見John Rawls, *The Idea of an Overlapping Consensus*, 7(1) OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES 1, 1-25 (1987).

179 翁岳生（註78），頁15。

180 引自鄭建才（註40），頁433。

181 *Christine Landfried*, Die Wahl der Bundesverfassungsrichter, in: Ooyen/Möllers (Hrsg.), *Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System*, 2. Aufl., 2015, S. 373.

伍、結論

近來各界關心為什麼司法院大法官解釋變少、歧異變大，此現象和制度規則有什麼樣的關連性。司法院認為，依現行大法官審理案件法，大法官解釋憲法，必須三分之二多數高門檻，導致解釋案件少。2019年1月憲法訴訟法公告，三年後實施。憲法訴訟法將解釋憲法的門檻降低為現有總額過半數同意。司法院樂觀表示，此有助於解釋案件量的增加。新制是否如預期發揮作用仍有待考驗。鑒往未必知來，對以往經驗的重新建構，有助於緩解現有問題產生的焦慮，同時投射未來解決路徑的曙光。在憲法訴訟法二年後實施之前，重新建構大法官解釋為何數量變少，歧異變大，依然深具時代意義。

本文採策略行為模型解釋，司法院釋字第76號解釋宣示立法院、監察院以及國民大會相當於民主國家國會，立法院加倍奉還制訂司法院大法官會議法，引進解釋高門檻與不同意見書等，試圖限制司法院大法官的解釋權。現行司法院大法官審理案件法確實造成矛盾，越是要求解釋有高度共識，必須跨過三分之二門檻，解釋量越少，而每個解釋的分別意見書越多，越沒有形式上的共識。高門檻不利於大法官三人小組和審查會受理案件，受理後僅能透過冗長的協商達成妥協才能跨越門檻。第四屆大法官透過會前會與聯誼強化彼此關係，克服高門檻。2003年後大法官不得連任，任期個別計算，大法官個人意識抬頭，與第四屆內部關係有所轉變。統一解釋憲法或解釋法律是否違憲案件妥協性較大，大法官撰寫協同意見書以明志的比例較高，2000年以後協同意見書的數量開始超越不同意見書，也受到這些制度改變的影響。

解釋日少、歧異日增也反和其他制度交互影響。人民聲請案越多，大法官受理越少，危機日增。大法官比較容易接受法官聲請案，係出於大法官策略選擇。三分之一以上立法委員聲請解釋具有

強化大法官正當性功能，因立法委員選制變更面臨被取消的危機。大法官認為案件違憲才會舉行言詞辯論。受門檻限制，大法官會等待解釋做成的適當時間。第四屆大法官透過非正式連誼，軟化高門檻限制。2003年後大法官因新人效應，導致協商與妥協更加困難。透過橫看成嶺側成峰的解釋有助於達成妥協。

參考文獻

1. 中文部分

- 司法院（1998），大法官釋憲史料，臺北：司法院。
- 史錫恩（1997），我國釋憲制度之檢討與改進，收於：楊建華教授七秩誕辰祝壽論文集編輯委員會編，法制現代化之回顧與前瞻——楊建華教授七秩誕辰祝壽論文集，頁198-205，臺北：元照。
- 吳庚（2004），憲法的解釋與適用，3版，臺北：三民。
- （2005），社會變遷與憲法解釋，收於：湯德宗編，憲法解釋之理論與實務（四），頁1-7，臺北：中研院法律學研究所籌備處。
- 吳庚、陳淳文（2015），憲法理論與政府體制，增訂3版，臺北：三民。
- 吳信華（2013），二〇一三年「司法院大法官審理案件法修正草案」評析II，台灣法學雜誌，227期，頁1-19。
- （2014），大法官釋憲「程序」與「實體」的交錯，月旦法學雜誌，226期，頁119-132。
- 李念祖（2013），扭曲的特別多數不是憲法訴訟的正當程序——我看「司法院大法官審理案件法」修正草案，台灣法學雜誌，222期，頁18-20。
- （2015），昨日、今日、明日，論權力分立的憲法解釋方法——以我國釋憲之政治正確意識為觀察中心，憲政時代，41卷2期，頁179-237。
- 李建良（2000），不同意見書與釋憲制度，收於：憲法理論與實踐（二），頁415-460，臺北：學林。
- 林子傑（2011），認識大法官解釋的第一本書，臺北：五南。

- 林佳和（2014），憲法法院不同意見書制度之再思考——以德國經驗為中心，輔仁法學，48期，頁117-185。
- 林紀東（1958），司法院大法官會議法之檢討，政治評論，1卷8期，頁16-18。
- 翁岳生（1976），憲法之維護者，收於：行政法與現代法治國家，6版，頁475-480，臺北：自版。
- （1994），論行政處分，收於：法治國家之行政法與司法，頁9-35，臺北：月旦。
- （1994），論司法院大法官會議之功能，收於：法治國家之行政法與司法，頁351-369，臺北：月旦。
- （1994），大法官功能演變之探討，收於：法治國家之行政法與司法，頁411-445，臺北：月旦。
- （1998），我國釋憲制度之特徵與展望，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁285-323，臺北：司法院。
- （2007），我國憲法訴訟制度之展望，中研院法學期刊，創刊號，頁1-62。
- （2009），憲法之維護者——省思與期許，收於：廖福特編，憲法解釋之理論與實務（六）（上冊），頁1-169，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
- （2014），司法院大法官釋憲制度新發展，憲政時代，39卷4期，頁2-23。
- （2016），法律作為志業，世新法學，9卷2期，頁259-277。
- 涂浩如（1959），司法院大法官會議法釋論，法學叢刊，4卷1期，頁40-60。
- 張文貞（2013），司法院大法官解釋引用外國法及判決之實證研究——大法官留學背景作為引用的關鍵因素，收於：張永健編，2011司法制度實證研究，頁33-83，臺北：中央研究院法律學研究所。

張特生（1997），大法官會議的經驗談及改進意見，憲政時代，22卷4期，頁8-13。

許宗力（2006），大法官釋憲權行使的程序及範圍——從大法官審理案件法與修正草案之檢視談起，收於：憲法與法治國行政，2版，頁87-130，臺北：元照。

——（2014），2013年憲法發展回顧，臺大法學論叢，43卷特刊，頁1031-1074。

——（2014），俠義法律人奧比·薩克斯大法官，收於：奧比·薩克斯著，陳毓奇、陳禮工譯，斷臂上的花朵，頁15-18，臺北：麥田。

——（2016），邁向2.0版的憲法訴訟程序——評新版大法官審理案件法草案，收於：台灣法學會編，台灣法學新課題（十一），頁1-11，臺北：元照。

陳英鈴（2004），基本權利訴願的結構性變遷——從比較法論基本權利訴願的對象與判決拘束力，收於：氏著，憲政民主與人權，頁85-180，臺北：新學林。

——（2004），憲法機關權限爭訟，收於：憲政民主與人權，頁1-83，臺北：新學林。

陳淑芳（1999），法院判決之不同意見書——德國法學界對此一問題之討論，政大法學評論，62期，頁105-127。

陳新民（2015），如何強化憲法與基本人權「維護者」的體系功能——我國釋憲制度的今日與明日，軍法專刊，61卷3期，頁1-32。

陳瑞堂（1997），釋憲制度中有關程序運作方式的問題，憲政時代，22卷4期，頁14-18。

湯德宗（2014），大法官解釋不同意見的實證研究，收於：違憲審查與動態平衡——權力分立新論（卷二），增訂四版，頁417-474，臺北：天宏。

- 楊子慧（2014），大法官解釋制度的司法化變革——憲法解釋的形成制度探討，東吳法律學報，25卷4期，頁49-93。
- 楊與齡（1998），司法規則制定權與大法官審理案件程序法規之制定及修正，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，臺北：司法院。
- 廖義男（2015），從釋憲經驗談釋憲理論與程序，收於：憲法及行政法制，頁50-94，臺北：元照。
- （2016），司法院大法官解釋之權利救濟功能，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，審判獨立與權利救濟、行政訴訟之發展與變革——海峽兩岸公法學論壇論文集（三），頁3-26，臺北：新學林。
- 劉鐵錚（1998），不同意見書之研究，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁375-410，臺北：司法院。
- （2003），大法官會議不同意見書之理論與實際，臺北：三民。
- 鄭健才（1998），大法官行使解釋權的程序規範，收於：司法院編，司法院大法官釋憲五十週年紀念論文集，頁411-435，臺北：司法院。
- 蘇永欽（2008），司法院大法官審理案件法修正芻議，收於：尋找共和國，頁255-332，臺北：元照。
- （2013），部門憲法的基本思維——一個在職大法官心所謂危的自剖，台灣法學雜誌，226期，頁89-102。
- （2013），憲法裁判的評決與書寫，收於：國立政治大學法學院公法學中心編，公法研究的世代對話：法治斌教授逝世十週年紀念論文集，臺北：新學林。
- 蘇彥圖（2014），釋憲時刻——初探司法院大法官的議程設定及其憲政效應，憲政時代，39卷4期，頁25-69。

2. 外文部分

- Brunner, Georg (2002), Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im europäischen Raum, in: Baer/Lepsius/Schönberger/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge, Bd. 50, Tübingen: Mohr Siebeck, S. 191-256.
- Christian, Burkiczak (2015), in: Burkiczak/Dollinger/Schorkopf (Hrsg.), BVerfGG-Kommentar, München: C.F. Müller, § 30.
- Corley, Pamela C., Amy Steigerwalt, and Artemus Ward. 2013. *The Puzzle of Unanimity: Consensus on the United States Supreme Court*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Dalla Pellegrina, Lucia, Nuno Garoupa, and Shirley Ching Ping Lin. 2012. Judicial Ideal Points in New Democracies: The Case of Taiwan, *National Taiwan University Law Review* 7:123-165.
- Epstein, Lee, and Jack Knight. 1998. *The Choices Justices Make*. Washington, D.C.: A Division of Congressional Quarterly Inc.
- Epstein, Lee, and Martin, Andrew D. 2014. *An Introduction to Empirical Legal Research*. Oxford: Oxford University Press.
- Epstein, Lee, and Tonja Jacobi. 2010. The Strategic Analysis of Judicial Decisions. *Annual Review of Law and Social Science* 6:341-358.
- Epstein, Lee, Jeffrey A. Segal and Harold J. Spaeth. 2001. The Norm of Consensus on the U.S. Supreme Court. *American Journal of Political Science* 45:362-377.
- Epstein, Lee, William M. Landes, and Richard A. Posner. 2013. *The Behavior of Federal Judges: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice*. Cambridge MA/London: Harvard University Press.
- Farahat, Anuscheh (2016), Das Bundesverfassungsgericht, in:

- Bogdandy/Grabenwarter/Huber (Hrsg.), *Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, Ius Publicum Europaeum*, Bd. VI, Heidelberg: C. F. Müller, S. 81-158.
- Frankfurter, Felix. 1949. "The Administrative Side" of Chief Justice Hughes. *Harvard Law Review* 63:1-4.
- Gadamer, Hans-Georg (1990), *Wahrheit und Methode – Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, 6. Aufl., Tübingen, J.C.B. Mohr.
- Garoupa, Nuno, Veronica Grembi, and Shirley Ching-ping Lin. 2011. Explaining Constitutional Review in New Democracies: The Case of Taiwan. *Pacific Rim Law & Policy Journal* 20:1-40.
- Ginsburg, Tom. 2003. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginsburg, Tom, Hong Sik Cho, Narufumi Kadomatsu, and Jiunn-Rong Yeh. 2008. Judicial Review in New Democracies, Constitutional Courts in Asian Cases. *National Taiwan University Law Review* 3:143-179.
- Ginsburg, Ruth Bader. 2010. The Role of Dissenting Opinions. *Minnesota Law Review* 95:1-8.
- Hagle, Timothy M. 1993. "Freshman Effects" for Supreme Court Justices. *American Journal of Political Science* 37:1142-1157.
- Hall, Peter A., and Rosemary C. R. Taylor. 1996. Political Science and the Three New Institutionalism. *Political Studies* 44:936-957.
- Hesse, Konrad (1999), *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, 20. Aufl., Heidelberg: C. F. Müller.
- Huntington, Samuel P. 1991. Democracy's Third Wave. *Journal of Democracy* 2(2):12-34.
- Hwang, Jau-Yuan. 2012. Taiwan's Constitutional Court from 2003 to

- 2011: New Appointments and Different Performance. *Seoul Law Journal* 53(2):41-63.
- Landfried, Christine (2015), Die Wahl der Bundesverfassungsrichter, in: Ooyen/Möllers (Hrsg.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im Politischen System, 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 369-388.
- Luhmann, Niklas (1990), Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, Rechtshistorisches Journal 9, S. 176-220.
- (1993), Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Moffett, Kenneth W., Forrest Maltzman, Karen Miranda, and Charles R. Shipan. 2016. Strategic Behavior and Variation in the Supreme Court's Caseload Over Time. *Justice System Journal* 37:20-38.
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pearson, Karl. 1911. *The Grammar of Science*. 3d ed. London: Adam and Charles Black.
- Popkin, William D. 2007. *Evolution of the Judicial Opinion — Institutional and Individual Styles*. New York, NY: New York University Press.
- Posner, Richard A. 2008. *How Judges Think*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . 2010. Response, Some Realism about Judges: A Reply to Edwards and Livermore. *Duke Law Journal* 59:1177-1186.
- Rawls, John. 1987. The Idea of an Overlapping Consensus. *Oxford Journal of Legal Studies* 7(1):1-25.
- Roberts, Jr., John G. 2005. Oral Advocacy and Re-emergence of a Supreme Court Bar. *Journal of Supreme Court History* 30:68-81.
- Schlaich, Klaus/Korioth, Stefan (2001), Das Bundesverfassungsgericht,

5. Aufl., München: C. H. Beck.
- Schmidt, Vivien A. 2008. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. *Annual Review of Political Science* 11:303-326.
- . 2010. Taking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change through Discursive Institutionalism as the Fourth ‘New Institutionalism’. *European Political Science Review* 2(1):1-25.
- Staton, Jeffrey K., and Vanberg, Georg. 2008. The Value of Vagueness: Delegation, Defiance, and Judicial Opinions. *American Journal of Political Science* 52:504-519.
- Stüwe, Klaus (2015), Bundesverfassungsgericht und Opposition, in: Ooyen/Möllers (Hrsg.), Handbuch Bundesverfassungsgericht im Politischen System, 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 349-368.
- Su, Yen-Tu, and Han-wei Ho, The Causes of Rising Opinion Dissensus on Taiwan’s Constitutional Court, 1-34. Available at <http://idv.sinica.edu.tw/yentusu/su2016e.pdf>.
- Sunstein, Cass R. 2015. *Constitutional Personae: Heroes, Soldiers, Minimalists, and Mutes (Inalienable Rights)*. New York, NY: Oxford University Press.
- . 2015. Unanimity and Disagreement on the Supreme Court. *Cornell Law Review* 100:769-823.
- Sunstein, Cass R., David Schkade, Lisa M. Ellman, and Andres Sawicki. 2006. *Are Judges Political? An Empirical Analysis of the Federal Judiciary*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Urofsky, Melvin I. 2015. *Dissent and the Supreme Court: Its Role in the Court’s History and the Nation’s Constitutional Dialogue*. New York, NY: Vintage.

- Vorländer, Hans/Brodocz, André (2006), Das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht - Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, in: Vorländer (Hrsg.), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 259-295.
- Weber, Max (1994), Politik als Beruf, in: Mommsen/Wolfgang J. (Hrsg.), Max Weber-Studienausgabe, Bd. I/17, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 35-88.

Consensus and Dissensus:

On the Quantity Crisis of the Taiwan Constitutional Court

*In-Chin Chen**

Abstract

Why has the Taiwan Constitutional Court (TCC) decided fewer cases while the number of separate opinions has increased remarkably? The Judicial Yuan believes that this institutional disorder manifests itself in the current law where passing a constitutional interpretation requires a high threshold. The Constitutional Court Procedure Act (CCPA) promulgated in 2019, on the other hand, intends to lower the threshold for constitutional interpretation. Before the implementation of the CCPA in 2022, re-constructing and explaining why the Court's docket shrinks when there is deep dissensus among Grand Justices remains a contemporary issue.

This article adopts a strategic model of judicial behavior to buttress the diagnosis of the Judicial Yuan with several findings about Grand Justices. For instance, the practice of defensive denial to review a case is commonly adopted by Justices in the hope of reserving the limited resources for the most significant cases or avoiding engaging in arduous cases. Cases referred by judges were more likely to be accepted by the Court. However, legislators from the minority parties may find it more difficult to file for constitutional interpretations after 2005. Moreover, Grand Justices tended to hold an oral hearing prior to holding a case (partially) unconstitutional. While difficult cases need more time to arrive at a compromise among Grand Justices, ambiguous interpretations and separate concurring and/or dissenting opinions in fact help to seek

* Professor, Graduate Institute of Law and Government, National Central University.

such a compromise. Only some of these findings may stand the test of time, and the consequences of the CCPA remain to be studied in the future.

KEYWORDS: strategic model, shrinking docket, separate opinions, quorum for passing interpretation, ambiguity of opinions.